

미국 수출관리규정(EAR) 매뉴얼

2020.11



미국 수출관리규정(EAR) 매뉴얼

2020.11



contents

본 매뉴얼은 한국무역협회가 회원사의 수출입 활동에 도움을 드리기 위해 참고자료로 제작해 배포하는 것으로, 본 매뉴얼에 근거한 제반 경영상의 결정에 대해 한국무역협회는 법적 책임을 지지 않음을 알려드립니다.

제1장 미국 수출관리규정(EAR) 개관	02
A. 특정 품목의 EAR 적용 여부에 대한 판단	03
1. 최소 허용 기준	05
2. 해외 직접 생산 제품 규정	07
B. 특정 물품의 허가 필요 여부에 대한 판단	11
1. 분류	11
2. 목적지	11
3. 최종 소비/최종 소비자 통제 - 일반론	14
4. 군사 최종 소비자 규정(Military End User Rule)	14
C. 허가 면제(License Exception)	16
D. 일반적인 금지 사항(General Prohibitions)	17
E. 기록 보관 의무	18
제2장 허가 신청 절차	20
A. 신청 방법	20
B. 필요 정보	21
C. 정부의 검토	22
D. 허가 신청 승인 가능성을 높이기 위한 방법	23
제3장 산업안보국(BIS)의 현장 조사 대비	24
A. 준법 정책 및 프로그램	24
B. 현장 조사 수검을 위한 준비	27
제4장 잠재적 EAR 위반 사례에 대한 대처	29
A. EAR 위반	29
B. 자발적인 자기 공시(Voluntary Self-Disclosures)	30
C. 제재 조치에 따른 잠재적 결과	32
D. 처벌	33
부록 미국의 대 화웨이 제재	35
매뉴얼 영어 원문	37

제 1 장

미국 수출관리규정(EAR) 개관

미 수출관리규정(Export Administration Regulations, 이하 EAR)은 당초 ‘1979년 수출 관리법(EAA)’에 의거 시행되었다. 동 법은 2000년에 효력이 경과했지만, 당시 미 의회는 해당 법률을 적기에 갱신하지 못했다. 이에 따라 기존의 수출 통제 제도의 운영을 위해 대통령은 국제긴급경제권한법(IEEPA, International Emergency Economics Powers Act)의 긴급 권한에 따라 EAR을 재공표했다. 이로부터 18년이 지난 2018년, EAR은 의회에서 수출통제개혁법(ECRA, Export Control Reform Act) 형태로 공식 부활했다. 상기한 바와 같이 현재 수출통제개혁법(ECRA)은 EAR의 법적 근거인데, 사실상 당초 1979년 수출 관리법(EAA) 통과 이후 EAR의 형식이나 운영 면에서 큰 변화는 없었다.

EAR은 ‘EAR의 적용을 받는’ 모든 ‘품목’과 관련한 수출, 재수출 그리고 국내 거래를 규제한다. EAR에서 ‘수출’은 미국 외 지역으로의 선적, 또는 지역과 관계없이 미국인 이외의 자에게 통제 대상 기술이 이동하는 경우를 의미한다.¹ ‘재수출’은 미국이 아닌 두 국가 또는 미국인이 아닌 두 사람 간의 선적 또는 전달을 말한다.² ‘이전(transfer, 동일 국가 내)’이란 한 국가 내에서 두 당사자 사이에 이루어지는 선적 또는 이동을 말한다.³ 본 매뉴얼에서 통상적으로 언급하는 ‘수출, 재수출, 그리고 이전’은 EAR에 따라 허가가 필요하고, 허가가 없으면 거래가 금지되는 경우를 의미한다. 예를 들어, 중국의 한 기업에서 중국 내의 다른 기업으로 특정 품목을 선적한다 하더라도 ‘EAR 적용 대상인 선적’이라고 했을 때는 해당 거래가 중국에서만 이루어졌다 해도 미국 정부의 허가가 필요한 경우로 본다. 본 매뉴얼은 때로 편의상 단순히 ‘수출’ 또는 ‘수출업자’라고만 표시하겠지만, 어떻게 표시하든 간에 그 의미는 ‘수출’의 경우에만 규제가 부과된다는 의미는 아니다. 즉, EAR상의 모든 제한 및 규칙은 ‘수출’, ‘재수출’ 및 ‘이전(동일 국가 내)’에 모두 동등하게 적용된다.

1. 15 C.F.R. 파트 734. (본 매뉴얼에서 C.F.R 이란 미국 연방규정집, 즉 Code of Federal Regulations 를 의미. C.F.R 앞의 숫자 15는 통상 및 거래를 다룬 규정집의 15권이란 뜻-역주)

2. *Ibid.*

3. *Ibid.*

본 규정에서 ‘품목(item)’이라는 용어는 ‘상품(commodity), 소프트웨어, 그리고 기술’을 뜻한다.⁴

- ‘상품(commodity)’이란 ‘기술 및 소프트웨어를 제외한 모든 물품, 물질 또는 공급품을 뜻한다. ‘기술’은 특정 품목의 개발, 제품, 사용, 운영, 설치, 유지, 보수, 개선, 또는 재조립에 필요한 정보를 뜻한다.’⁵
- ‘소프트웨어’는 일반적으로 기계로 해독 가능한 대상물 코드, 그리고 경우에 따라서 소스 코드를 포함하는데, EAR에서는 때로 소스 코드를 ‘기술’의 한 형태로 취급하기도 한다.⁶
- ‘기술’은 문서 또는 구두 의사소통, 청사진, 설계, 사진, 계획안, 다이어그램, 모델, 공식, 표, 엔지니어링 설계 및 명세, CAD 파일, 매뉴얼 또는 문서, 전자 매체 또는 품목에 대한 비주얼 조사를 통해 드러난 정보 등을 말한다.
- ‘공개된(published)’ 즉, 제한 없이 무료로 대중에 공개하는 소프트웨어 및 기술은 EAR의 적용을 받지 않는다(다만 오픈 소스 암호화 소프트웨어의 공용 인터넷상 위치는 ‘공개’ 여부 판단 전에 미국 정부로 송부해야 한다).⁷

A. 특정 품목의 EAR 적용 여부에 대한 판단

이하의 품목은 EAR의 적용 대상이다.

- (1) 미국 자유 무역 지역을 포함한 미국 내 모든 물품, 미국 기반 시설을 이용해 보관하는 경우, 소프트웨어를 미국 외 당사자에게 보내는 경우를 비롯해 미국을 경유해 한

4. 15 C.F.R. § 772.

5. *Ibid.*

6. *Ibid.*

7. 15 C.F.R. § 742.15에 의하면, 공개적으로 이용 가능한 모든 암호화 소스 코드는 EAR 적용 대상이다. 개발자는 미국 정부에 ‘공개적으로 이용 가능한 암호화 소스 코드의 인터넷상 위치(예를 들어 URL 또는 인터넷 주소)를 이메일로’ 미국 정부에 통지하거나… 그들에게 공개적으로 이용 가능한 암호화 소스 코드의 사본을 제공하거나… 모든 경우에 통지 또는 사본은 crypt@bis.doc.gov 및 enc@nsa.gov로 제출한다. 대개 원 개발자가 소프트웨어에 대한 통제를 해제하기 위해 미국 정부에 통지하지만, EAR에 의하면 소프트웨어를 ‘오픈 소스’로 취급하도록 하기 위해 해당 소프트웨어의 인터넷상 위치를 정부에 통지하는 것은 누구나 할 수 있다.

국가에서 다른 국가로 이동하는 물품(예를 들어, 미국 데이터 센터가 이용되는 경우, 미국 데이터 센터를 통과하는 모든 것은 EAR 적용 대상이다.)

- (2) 위치에 관계없이 모든 미국산 원산지 품목,
- (3) 통제 대상인 미국산 공산품과 합체된 외국산 공산품, 통제 대상인 미국산 소프트웨어와 함께 ‘포장된’ 외국산 공산품, 통제 대상인 미국산 소프트웨어와 부합된 외국산 소프트웨어, 그리고 통제 대상인 미국산 기술과 부합된 외국산 기술
 - 특정 품목의 경우 모든 수량, 그리고
 - 그 외 대부분의 품목의 경우, 최소허용 기준을 초과한 수량
- (4) 미국산 기술 또는 소프트웨어의 특정 외국에서의 직접생산 제품. ‘직접 생산제품’이라는 용어는 기술 또는 소프트웨어를 사용해 직접 생산한 산출물(프로세스 그리고 서비스 포함)을 말한다. 그리고
- (5) 미국 이외 지역에 위치한 공장 또는 공장의 주요 부분에서 생산된 미국산 기술의 직접 생산품인 특정 공산품⁸

이들 기준의 적용에는 복잡한 요소의 고려가 필요하나, 일반적으로 EAR은 미국에서 생산된 모든 상품 및 미국을 통해 이전된 모든 것을 포함한다. 이러한 적용 범위는 위 항목 (1) 및 (2)에 반영돼 있다.

EAR이 모든 상품, 소프트웨어, 또는 미국 외에서 생산된 기술 등을 그 대상으로 하는 것은 아니다. 미국산 재료를 상품, 소프트웨어 또는 기술에 합체했거나(예를 들어, 미국산 부품이 외국산 장비에 설치된 경우) 미국 소프트웨어 또는 기술을 상품 생산에 사용한 경우(예를 들어, 미국 지적 재산권이 외국산 하드웨어 제작에 사용된 경우)도 마찬가지다. 미국 외 생산자 및 개발자들은 미국 외 생산 물품에 포함된 요소와 관련해, 상품의 경우에는 재료와 부품이 무엇인지, 소프트웨어 또는 기술의 경우에는 U.S.코드나 기술 정보가 무엇인지 살펴 봐야 한다. 이러한 접근법은 **최소 허용 기준**(위 항목 (3))이라 불린다. 이와 별도로, **해외 직접 생산 제품 규정**(위 항목 (4)부터 (5)까지)에 의해서는, 미국 외 생산자들이 미국 외 생산 물품의 생산 또는 개발에 사용한(그러나 합체되지는 않은) 미국산 소프트웨어 또는 기술이

8. 15 C.F.R. § 734.3(a).

있는지, 있다면 무엇인지를 고려해야 한다. 종합하면, 이들 분석을 통해 어떠한 미국 외 물품이 EAR의 적용을 받는지 알 수 있다.

1. 최소 허용 기준

어떤 품목이 미국 외 지역에서 생산됐다면 그 품목에 대한 EAR 적용 여부 분석을 위해 살펴볼 사항은 해당 품목이 위에서 말한 ‘최소 허용’ 기준에 근거할 때 미국에서 통제하는 재료에 ‘합체(incorporate)’됐거나 ‘포장(bundle)’된 경우인지 여부다. EAR에 따르면 어떤 품목이 미국에서 통제하는 내용물에 ‘합체’됐거나 ‘포장’된 경우는 다음의 경우와 같다.

- 미국에서 통제하는 재료가 최소 허용 목적으로 ‘합체’됐다고 볼 경우는, 해당 품목이 외국산 장비의 기능에 필수적인 것일 때, 외국산 장비의 판매 시 관습적으로 해당 품목이 포함되는 것일 때, 그리고 외국산 품목과 함께 재수출되는 경우일 때이다. 미국산 소프트웨어는 외국산 공산품과 함께 ‘포장’되는 경우도 있다. [‘포장’이란 소프트웨어가 해당 품목과 함께 재수출된 경우로, 함께 구성되기는 했으나 반드시 물리적으로 해당 아이템과 일체되지는 않은 경우를 말한다.] 최소 허용 기준의 정의를 위해, 외국산 공산품 또는 소프트웨어를 설계하거나 생산하는 데에 사용된(그러나 공산품 또는 소프트웨어 그 자체와 합체가 된 것은 아닌) 공산품 및 소스 코드는 그와 같은 외국산 공산품 또는 소프트웨어와 합체되었다고 보지는 않는다.⁹

일반적으로, 최소 허용 기준 계산법은 기술, 소프트웨어 및 하드웨어에 개별적으로 적용해야 한다. 그러나 BIS는 2008년 시스템 및 소프트웨어가 개발되고 고객에게 전달되는 방식에 상응하도록 *최소 허용* 기준을 개정했다. 새로운 기준에 따르면, ‘포장된’ 미국산 소프트웨어의 경우 그 가치를 하드웨어의 가치와 비교해 평가한다. 그러나 이러한 예외는 낮은 수준에서 통제되는 소프트웨어(EAR99) 또는 ‘반테러리즘’에 대해서만 적용한다. 그러므로 이는 대부분의 상업용 소프트웨어에는 적용하나 보다 민감한 애플리케이션을 위해 커스터마이징된 소프트웨어에는 적용하지 않는다. 보다 높은 수준에서 통제하는 소프트웨어의 경우에는 소프트웨어와 하드웨어의 가치를 개별적으로 평가해야 한다.

9. 15 C.F.R. § 734의 부록 2.

특정 품목을 품목의 총 가치와 비교해 평가했을 때 미국에서 통제되는 재료의 금액보다 최소 허용 기준상 그 미만일 때, 해당 품목은 EAR의 적용을 받지 않는다.¹⁰ 최소 허용 최저치는 다음과 같이 정의한다.

- 쿠바, 이란, 북한, 수단, 그리고 시리아로 수출되는 경우, 최소 허용 최저치는 미국산 재료가 10%까지인 경우이다.¹¹
- 한국을 포함한 기타 국가로의 수출의 경우에는 허용치가 25%이다.¹²
- 일부 품목은 매우 민감해 최소 허용 기준이 없는데, 즉 그러한 경우에는 외국산 제품에 해당 품목이 극소량이라도 들어가면 자동으로 'EAR의 적용 대상'이 된다.

가치를 평가하는 이 방법을 요약하면 아래와 같다.

- 어떤 품목 내 포함된 통제되는 미국산 재료의 양은 해당 품목에서 완제품에 합체된 모든 미국산 재료 중 목적 국가로의 수출 허가가 필요한 재료의 가치를 산출해 결정된다.
- 먼저, 수출업자는 모든 미국산 재료의 수출통제분류번호(ECCN)을 살펴본 뒤, 이들 재료가 목적 국가로 재수출될 경우에 허가가 필요한 ECCN이 무엇인지 판단한다.
- 목적 국가로의 이전을 위해 허가가 필요한 미국산 재료('통제된 미국산 재료'로 불리기도 함)의 공정 시장 가치를 평가하는데, 이는 즉, 특수 관계가 없는 회사의 경우에 제3의 생산자에게 해당 품목이 이전될 때의 실제 비용을 계산한다.
 - 아마 의외이겠지만, 수출업자는 내용물이 '통제되는' 것인지 여부를 판단할 때 최종 소비자 또는 최종 소비에 대한 특정한 통제에 대해 고려하지 않아도 된다. 예를 들어, 인쇄회로기판PCBA(Printed Circuit Board+Assembly)의 EAR 부품은 중국으로 수출되는 경우 대개 허가가 필요 없고, 따라서 최소 허용 계산법에 따르면 '통제되는' 것으로 간주되지 않는데, 이는 PCBA가 '엔티티 리스트'에 따라 모든 물품이 EAR에 따라 허가가 필요한 화웨이로 판매되는 경우에도 마찬가지다 (아래에 기술).

10. 15 C.F.R. § 734.3(a)(3)(ii).

11. *Ibid.* § 734.4(c).

12. *Ibid.* § 734.4(d).

- 이 가치는 다시 최소 허용 퍼센티지 산출을 위해, 판매되는 시장에서의 외국산 제품의 가격(해당 품목에 공정 시장 가치가 없거나 무료일 경우는 총 생산 비용)으로 나눈다.¹³
 - ‘생산 비용 방법’ 사용 시에 해당 비용은 일관성 있고 상업적으로 합리적인 접근법에 따라 산출해야 한다. 그러므로 해당 비용은 투입물(즉, 구입된 또는 제3자로부터 획득한 구성물) 및 품목 개발에 소요된 노동 비용을 포함한다.(예를 들어, 어떤 회사가 책상을 만드는 경우, 책상 생산 비용은 나무 구입비 및 목수 임금의 합이다. 그 나무가 미국산이면, 최소 허용 기준상 미국산의 %는 -- 그 나무가 ‘통제된’ 품목일 경우 -- 나무/나무+임금이다.)

기술(즉, 기술 정보)의 경우에는 다음 내용이 적용된다. 미국산 재료가 ‘기술’(즉, 외국산 기술 정보에 미국산 기술 정보가 부합된 경우)인 경우, 해당 ‘기술’을 이전하려는 사람은 최소 허용 기준을 활용하기 전에 먼저 정보의 혼합과 관련해 미국 상무부에 1회성 보고서를 제출해야 한다.¹⁴ 이와 같은 보고 의무는 하드웨어나 소프트웨어의 이전을 위해 사용되는 최소 허용 기준의 사용에는 적용되지 않는다. 이는 오직 기술 이전의 경우에만 적용된다.

어떤 제품을 개발하는 데에 사용된 미국산 기술이 그 자체로는 최소 허용 기준에 따라 제품의 가치 대비 계산이 이루어지지 않는다고 하자. 그런 경우에 해당 기술 또는 소프트웨어가 ‘EAR의 적용 대상인지’ 여부는 다음 장에서 다룰 ‘EAR 적용 대상’ 해당 여부에 따른다(해외 직접 생산 제품 규정). 예를 들어, 마이크로칩 생산에 미국산 설계도가 들어가는 경우, 설계도(마이크로칩의 부품이 아님)는 마이크로칩의 최소 허용 분석에 따라 계산되지 않는다. 해당 설계도로 인해 그 마이크로칩이 EAR 적용 대상인지 여부는 아래에서 설명할 직접 생산 제품 규정에 의한다.

2. 해외 직접 생산 제품 규정

EAR에 따르면, 통제된 미국산 기술 또는 소프트웨어의 직접 생산물인 외국산 제품 또는 외국 공장에서 생산된 미국 원 기술 또는 소프트웨어의 직접 생산품은 ‘해외 직접 생산 제품 규정’이 적용되는 경우에만 EAR의 적용 대상이다.¹⁵

13. 파트 734의 부록 2, ‘Guidelines for *De Minimis* Rules.’ 참조

14. 15 C.F.R. § 734.3(c)(3).

본 규정에 따르면 대부분의 최종 사용자, 고객, 그리고 국가에 대해 아래 두 가지 조건이 충족되는 경우라면 외국산 품목의 수출, 재수출, 이전을 위해서는 허가가 필수이다.

- 첫째, 외국산 품목 제작에 사용된 미국 기술 또는 소프트웨어는 외국 생산자가 해당 기술이나 소프트웨어를 수령하기 전에 서명한 특별 ‘서면 보증’ 문서를 사용해 외국 생산자에게 이전돼야 한다.¹⁵ 이 서면 보증 요구는 해당 기술이 미국에서 수출된 것이고 ‘국가 안보’(NS) 이유로 고도의 통제가 이루어지는 것일 경우에만 적용된다.
- 둘째, 해당 외국산 품목은 그 자체로 ‘NS(National Security)’ 통제에 따라 ECCN에 해당하는 것이어야 한다.¹⁶

미국 기술의 산물인 공장에서 생산된 외국산 제품에 대한 두 가지 조건은 유사하다. 또한 이들 조건은 해당 공장 및 수출될 제품을 지원하는 기술이 국가 안보를 이유로 통제되는 경우일 때만 적용된다. 이 두 가지 조건을 충족하면, 외국에서 생산된 관련 물품은 ‘EAR 적용 대상’이 된다.¹⁷ 그렇지 않으면, ‘해외 생산 제품 규정’을 외국산 제품에 적용하지 않고, 그 외국산 제품은 EAR 적용 대상이 아니다.

미국 밖에서 개발된 게임 소프트웨어를 예로 들어 보자. 외국산이기 때문에 해당 게임 소프트웨어는 ‘미국산’ 물품은 아니다. 심지어 해당 물품이 미국의 게임 개발 소프트웨어 플랫폼을 사용해 개발했다고 하더라도 ‘해외 직접 생산 제품 규정’을 적용하지는 않는다. 게임 소프트웨어는 EAR의 적용을 받는다고 하더라도 EAR99에 따라 분류된다. 그러므로 이는 NS를 이유로 통제받는 것이 아니고, 어떤 수준에서 게임 개발 플랫폼이 통제되는지도 중요하지 않다.

그러나 2020년 8월, BIS는 EAR 엔티티 리스트에 올라 있는 ‘화웨이 테크놀로지 주식 회사’ 및 이 회사의 많은 계열사(이후 ‘화웨이’로 총칭)에 적용되는 특별 규정을 마련했다. 엔티티 리스트는 허가 없이는 기본적으로 리스트에 등재된 엔티티(그러한 ‘최종 소비자’ 통제는 아래에서 설명하는 세 가지 유형의 이전(transfer) 통제 중 하나다)들에게 모든 수출

15. *Ibid.* § 736.2(b)(3).

16. *Ibid.* § 736(b)(3)(ii)(A)(1).

17. *Ibid.* § 736(b)(3)(ii)(A)(2).

18. *Ibid.* § 736(b)(3)(ii)(B).

또는 이전을 제한하는 일종의 블랙리스트다. 화웨이와 관련된 외국산 품목의 경우, 해외 직접 생산 제품 규정의 범위는 보다 넓다. 즉 EAR은 아래와 같은 사항을 ‘인식(knowledge)’했을 경우 허가 또는 허가 면제 없이 외국산 품목을 재수출하거나 해외에서 수출하거나 또는 (동일 국가 내에서) 이전하는 것이 위반이라고 규정한다.

- 외국산 품목이 화웨이가 생산, 구매 또는 발주한 어떤 ‘부분’, ‘부품’ 또는 ‘장비’의 ‘생산’ 또는 ‘개발’을 위해 이에 합체되거나 사용될 경우, 또는
- 외국산 물품 관련 거래에 화웨이가 일방의 당사자인 경우, 예를 들어 화웨이가 ‘구매자’, ‘중간 인수자’, ‘최종 인수자’ 또는 ‘최종 소비자’인 경우

EAR상의 ‘인식’은 ‘정황이 존재하거나 존재할 것이 실질적으로 명백하다는 명확한 인지 뿐만 아니라, 현재 및 미래에 존재 가능성이 높다는 인식까지 포함한다. 그러한 인식은 자신에게 알려진 사실 관계에 대한 의식적 무시 그리고 사실 관계에 대한 고의적 회피 등을 통해 추론될 수 있다.’ 고 넓게 규정하고 있기 때문에 이는 넓은 범위에 적용되는 제한이다.

일반적인 해외 직접 생산제품 규정과는 달리 화웨이에 구체적으로 적용되는 규정은 아래와 같은 많은 다른 품목을 포괄한다.

- *EAR이 적용되고 ECCN 카테고리 3, 4 또는 5에 명시된 ‘기술’ 또는 ‘소프트웨어’의 직접 생산품.* 해당 외국산 품목은 EAR이 적용되고 수출통제 분류번호(ECCN) 3D001, 3D991, 3E001, 3E002, 3E003, 3E991, 4D001, 4D993, 4D994, 4E001, 4E992, 4E993, 5D001, 5D991, 5E001가 부여된, 또는 EAR 파트 774의 부록1의 상무부 통제 리스트(CCL)에 기재된 ‘기술’ 또는 ‘소프트웨어’의 직접 생산품이다.
- *공장의 직접 생산품 또는 주요 구성물.* 외국산 물품은 미국 외 지역에 위치한 공장에서 생산되었거나 공장의 주요 구성 부분에서 생산된 것을 말하는데, 생산지가 미국인지를 불문하고 공장이나 공장의 주요 구성 부분 자체가 ECCN 3D001, 3D991, 3E001, 3E002, 3E003, 3E991, 4D001, 4D993, 4D994, 4E001, 4E992, 4E993, 5D001, 5D991, 5E001 또는 CCL의 5E991로 명시된 EAR 적용 미국산 ‘기술’ 또는 ‘소프트웨어’의 직접 생산품이다.

규정은 아래와 같은 사항도 명기하고 있다.

- ‘미국 외 지역의 공장의 주요 구성 부분’이란 특정 품목의 ‘생산’에 필수적인 장비를 말하는데, 이에 는 시험용 장비도 포함된다.
- ‘외국산 품목’에는 모든 외국산 웨이퍼가 포함되는데, 이는 모든 과정이 완료된 것인지 여부를 불문한다.

이 규정에서 다루는 ECCN에는 많은 혼한, 상업적으로 가용한 기술이 포함된다. 그러므로 예를 들어 PCBA(인쇄회로기판)의 반도체 부품이 ECCN 적용 대상인 미국 원기술로 만든 전자 테스트 장비의 공통부분을 이용해 만들어졌다면, PCBA가 화웨이를 위해 쓰이는 경우 해당 부품은 PCBA에 결합되기 위해 제3의 당사자에게 미국 정부의 허가 없이 전달될 수 없다. 요컨대, 이 새로운 금지 규정은 매우 포괄적이나 관련 부품 또는 상품 최종 공급망 내 어딘가에 화웨이가 있는 경우에만 적용한다.

어떤 제품이 EAR의 적용 대상인지를 판단하는 것은 복잡한 과정이다. 회사 내부적으로 이루어질 수도 있지만 BIS와의 협의를 통할 수도 있다. 특히, 수출업자들은 어떤 최종 소비, 최종 소비자, 그리고/또는 목적지를 언급하고, 특정한 거래에 대한 허가가 필요한지, 필요하다면 승인될 가능성이 있는지 등에 대해 BIS에 자문을 구할 수 있다.¹⁹ 그러나 수출업자들은 BIS의 자문 의견이 BIS를 구속해 미래에 허가 승인을 보장하는 것은 아니라는 점을 알고 있어야 한다. 그러나 외부 자문관의 조력이 필요할 정도로 리스크가 높은 수출이 관련된 경우에는 BIS의 자문을 구하도록 적극 권장한다.

19. *Ibid.* § 748.3.

B. 특정 물품의 허가 필요 여부에 대한 판단

위에서 분석한 바에 따라 특정 물품이 ‘EAR의 적용을 받는다면’, 해당 물품이 한 당사자로 부터 다른 당사자(미국인이 아닌 사람, 즉 미국 시민권자, 미국 영주권자 또는 자격 있는 난민/피난자, 또는 미국 내 미국 등록 회사가 아닌 경우)로 이전되는 경우, 심지어 그 두 당사자 모두 미국이 아닌 곳에 있다고 하더라도 이전이 이루어지기 전에 규정에 대한 확인이 이루어져야 한다. 이러한 분석 내용에 따르면 다음과 같은 3단계 과정, 즉 **분류, 목적지, 최종 소비/최종 소비자에 대한 평가**가 필요하다.

1. 분류

이전하는 행위자들은 **상무부의 통제 리스트(CCL: Commerce Contrl List)**를 검토해야 하는데, 이 리스트에는 수출통제 분류번호(ECCN : Export Control Classification Numbers)가 포함돼 있다. ECCN에는 특정 품목을 열거하고 어떤 수준에서 열거한 품목들이 EAR에 따라 통제되는지 자세히 설명하고 있다.²⁰ 그런데 어떤 품목이 CCL에 없으나 EAR의 적용을 받는다면, 이는 ‘EAR99’에 포함된 것인데, ‘EAR99’ 목록에는 없지만 낮은 수준에서 EAR 적용 대상이 되는 품목을 포괄적으로 나열한 것이다. 예를 들어 미국 내의 모든 연필, 책상 의자, 티셔츠, 그리고 종이 상자는 ‘EAR99’로 분류된다. 이러한 분류 절차는 강도 높고 기술을 요하는 과정이 될 수 있다. 품목 분류에 대한 적절한 기준에 관해 의문이 있다면 미국 정부의 가이드를 활용할 수 있는데, 이는 정부가 분류를 제공하는 ‘CCATS’라는 형태로 돼 있다. 그러나 기업들은 스스로 분류할 수 있는 권한을 부여받아, 미국 정부로부터 분류에 대한 확인을 받을 의무가 일반적으로 없다.

2. 목적지

EAR적용 대상 품목을 수출하려는 자는 해당 품목의 ECCN 및 수령자의 국가/지역을 확인해야 한다.

20. 15 C.F.R. 파트 774의 부록 1 참조.

- 어떤 품목이 CCL에 포함돼 있으면, 이를 이전하는 자들은 통상국가표를 검토한 다음 수령자의 국적(목적지가 다른 곳이라면 목적지도 확인)에 의해 허가가 필요한지 여부를 판단해야 한다.²¹ ‘통상국가표(Commerce Country Chart)’에는 세계 모든 국가 및 개별 ECCN에 따른 다양한 ‘통제의 이유’를 열거하고 있다. 이를 보면 이 표에서 어떤 국가의 경우 ‘통제 이유(reasons for control)’ 항목 아래 부분에 ‘X’ 표시가 있으면 허가가 필요하다는 의미다.

예를 들어, ECCN 3A002은 많은 첨단 전자 부품을 통제한다. 각 ECCN 상단의 박스에는 품목이 통제되는 이유가 적혀 있다.²²

3A002 General Purpose “Electronic Assemblies,” Modules and Equipment, as Follows (See List of Items Controlled).

LICENSE REQUIREMENTS

Reason for Control: NS, MT, AT

Control(s)	Country chart (see Supp. No. 1 to part 738)
NS applies to entire entry	NS Column 2
MT applies to 3A002.h when the parameters in 3A101.a.2.b are met or exceeded	MT Column 1
AT applies to entire entry	AT Column 1

아래 표에서 보듯이 어떤 회사가 3A002.b 물품을 알제리로 수출하고자 한다면 허가가 필요한데, 이는 알제리의 통상국가표 ‘NS Column2’ 아래에 ‘X’ 표시가 있기 때문이다. 그러나 한 회사가 동일한 3A002.b 물품을 아르헨티나로 수출하고자 하는 경우에는 허가가 필요 없는데, 이는 아르헨티나 ‘NS 2’ 아래에는 ‘X’ 표시가 없기 때문이다. 우리는 알제리와 아르헨티나 모두 ‘MT Column 1’에는 ‘X’ 표시가 있지만, 표에서 3A002.h에 따라 통제되는 유일한 품목은 ‘MT Column 1’을 위해 통제된다는 점을 확인했다(표를 보면 ‘MT’가 오로지 ‘3A002.h’에만 ‘적용’되며 일정 기준이 충족되는 경우에만 그러하다고 명시돼 있다).

21. 15 C.F.R. 파트 738의 부록 1.

22. EAR의 파트 742는 다양한 ‘통제 이유’의 구체적인 특성을 자세히 설명하나 통제는 대체로 EAR에서 달리 정하지 않은 한 통상국가표에서 ‘X’ 표시된 경우 경감될 수 있다.

SUPPLEMENT NO. 1 TO PART 738—COMMERCE COUNTRY CHART

[Reason for control]

Countries	Chemical and biological weapons			Nuclear nonproliferation		National security		Missile tech	Regional stability		Firearms convention	Crime control			Anti-terrorism	
	CB 1	CB 2	CB 3	NP 1	NP 2	NS 1	NS 2	MT 1	RS 1	RS 2	FC 1	CC 1	CC 2	CC 3	AT 1	AT 2
Afghanistan	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X		X		
Albania ^{2 3}	X	X		X		X	X	X	X	X						
Algeria	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X		
Andorra	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X		
Angola	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X		
Antigua and Barbuda	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		
Argentina	X					X		X	X		X	X		X		
Armenia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X			
Aruba	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X		
Australia ³	X					X		X	X							
Austria ³⁴	X					X		X	X			X		X		

- EAR에서는 개인의 국적을 최근 국적 또는 영주권을 기준으로 결정하는데, 다만 미국 시민권자, 미국 영주권자 또는 기타 특정 미국 난민/망명 신청자 등은 항상 미국인으로 평가해 통제의 예외를 적용한다. 그러므로 기술 또는 소프트웨어가 개인에게 이전된 경우에, 절차는 같으나 해당 개인은 위 표에서 ‘국가’를 기준으로 분류된다.
- 어떤 물품이 EAR99로 분류되는 경우에는 EAR 파트 746만을 확인하는데, 이는 이란, 시리아, 북한, 크림반도 및 쿠바에 대한 특별 엠바고를 다루는 부분이다. 현재 EAR99 품목은 EAR에서 이란과 관련한 통제가 없고, 대신 해외자산 통제국(OFAC)의 제재에서 이란 무역 제한과 관련해서는 EAR에 앞서 적용되는 내용들이 있다. OFAC 제재는 직간접을 불문하고 미국에서 이란으로 가는 모든 품목의 수출을 제한하나 이미 미국 외에 존재하는 EAR99 품목 같은 경우에는 예외를 적용한다. OFAC에서 대이란 수출을 승인하는 경우에 해당 승인은 EAR까지 포괄한다. 쿠바 및 다른 수출 엠바고 국가들의 경우에 EAR 및 OFAC 제재 모두가 적용되고 두 기관의 허가가 모두 필요하다.

3. 최종 소비/최종 소비자 통제 - 일반론

마지막으로 국가 수준의 통제와는 별도로, 이전을 하는 자들은 EAR 섹션744에 따른 최종 소비 및 최종 소비자 통제를 고려해야 한다. 이는 특정 당사자들에 대한 이전을 통제 하는데, 당사자의 국적을 불문하고 용도가 특정한 것이거나 당사자의 정체성 때문인 경우에 이루어진다(예를 들어 전통적인 미국 우방국의 엔티티도 제한받는 최종 소비자가 될 수 있으며, 목적 국가를 불문하고 핵무기 지원을 위한 이전은 모두 허가가 필요하다).

최근 들어 미국 정부는 EAR에 따른 최종 소비 통제를 대폭 확대했다. 이에 따르면 특정 엔티티 또는 부류의 사람들에 대한 특정한 이전(transfer)에 허가가 필요하고, 이는 주로 엔티티 리스트를 통해 이루어지며, 위에서 언급했듯이 여기에는 화웨이도 포함된다. BIS는 또한 유사하게 수출, 재수출, 그리고 동일 국가 내 이전을 제한하는 금지 대상자(Denied Persons) 리스트를 운영하고 있다.²³ 그 외 많은 다른 최종 소비/최종 소비자 통제는 매우 특정적이다. 단, 아래에서 다룰 군사 최종 소비자 규정은 예외다.

4. 군사 최종 소비자 규정(Military End User Rule)

덧붙여 BIS는 최근에 또한 소위 ‘군사 최종 소비 및 최종 소비자(military end use and end user rule) 규정’을 대폭 확대했는데, 이에 따라 EAR에 근거한 허가가 없는 경우 중국, 러시아 또는 베네수엘라에 폭넓은 종류의 물품 수출, 재수출 또는 이전을 금지한다. 대상 물품으로 상업용 전자 제품, 소프트웨어, 여러 민간 항공기, 선박, 그리고 군수 물자 부품이 군사적인 최종 소비 목적으로 쓰이는 경우 또는 ‘군사 최종 소비자’가 사용하는 경우에 동 내용을 적용한다.²⁴

‘군사 최종 소비자(military end user)’라는 개념은 광범위하며 해당 규정을 폭넓게 적용한다. 해당 정의는 전통적으로 군 관련 업체로 간주된 곳뿐 아니라, 많은 다른 정부 기관, 다른 군사 최종 소비자들을 ‘지원’하는 민간기관도 포함한다. 특히, 해당 규정은 ‘군사 최종 소비자’를 다음과 같이 정의한다.

23. <https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/denied-persons-list>. 참조.

24. 15 C.F.R. § 744.21.

- 국가에 소속된 군대(육군, 해군, 해병대, 공군 또는 해안 경비대), 주 방위군, 경찰, 정부 정보 또는 경찰 조직, 또는 ‘군사 최종 소비’를 지원하기 위한 활동이나 기능을 하는 사람 또는 조직²⁵

해당 규정은 ‘군사 최종 소비(military end use)’를 아래와 같이 정의한다.

- 미국 군수품 리스트(USML : U.S. Munitions List)에 묘사된 군 관련 물품에 합체 (22 CFR 파트 121, International Traffic in Arms Regulations), ECCN에서 ‘A018’로 끝나는 분류 번호 물품 또는 ECCN에서 ‘600 시리즈’에 해당하는 물품에의 합체, 또는 USML에서 운영, 설치, 유지, 보수, 오버홀, 리퍼, ‘개발’ 또는 ‘생산’을 지원하거나 이에 기여하는 물품, 또는 ECCN에서 ‘A018’로 끝나는 분류번호 물품 또는 ECCN에서 ‘600 시리즈’에 해당하는 물품

이러한 정의에 근거해, 규정은 규정이 적용되는 물품들이 군 또는 EAR 또는 미국 국제 무기거래규정(ITAR, U.S. International Traffic in Arms Regulations) 22 C.F.R. 파트 120-130에 따라 군 관련 물품을 개발하는 공급자들을 지원하는 (정부/군기관도 아닌) 민간 기업에 대한 규제 대상 물품 이전을 제한한다. 다시 말해, 규정은 ‘누가’ ‘군사 최종 소비자’인지에 대해 매우 포괄적으로 정의하고 있다.

이러한 금지 내용은 EAR의 ‘인식(knowledge)’에 대한 정의를 원용하고 있다는 점에서도 포괄적인 성격을 가진다. 해당 규정은 특히 ‘이전을 하는 자가 해당 물품이 전체적으로, 또는 부분적으로 ‘군사 최종 소비’ 목적을 위해… 또는 ‘군사 최종 소비자’를 위한 것임을 인식한 경우’의 이전을 금지한다. 위에서 언급한 바와 같이 EAR은 인식에 대해 ‘정황이 존재하거나 할 것이 실질적으로 명백하다는 명확한 확신뿐만 아니라 현재 및 미래의 존재 가능성이 높다는 점을 아는 경우까지 포함한다고 넓게 규정하고 있으므로 이는 넓은 범위에 적용되는 제한이다. 그러한 인식은 자신에게 알려진 사실 관계에 대한 의식적 무시 그리고 사실 관계에 대한 고의적 회피 등을 통해 추론될 수 있다.’고 정의한다.

결과적으로 중국, 러시아 또는 베네수엘라에서 군사급(grade) 품목을 다루거나 군을 위한 업무를 하는 회사는 ‘군사 최종 소비자’로 취급될 가능성이 높고, EAR 적용 품목의 수출을

25. Ibid.

위해서는 해당 품목이 군사 용도로 사용되지 않을 것임을 확실히 알고 있다고 하더라도 허가가 필요하다. 따라서 이들 국가, 특히 중국으로의 수출을 위한 실사 및 규정 준수를 위한 비용이 증가하는데, 당사자들은 이제 수출업자가 단지 인수자에게 민간용 물품을 판매하는 경우에도, 특정 인수자 또는 최종 소비자가 이 규정에 따른 ‘군사 최종 소비자’인지 판단해야 하기 때문이다.

C. 허가 면제(License Exception)

특정 수출에 허가가 요구되는 경우(예를 들어 특정 국적자 또는 최종 소비자), ‘허가 면제’가 적용되는 경우가 있을 수 있다. 예를 들어 허가 면제 ENC가 있는 경우, 절차에 따른 사후 보고를 이행한다는 전제 하에 EAR에 따라 대부분의 목적지로 가는 물품의 암호화 물품의 이전을 허용한다.²⁶ 허가 면제가 적용되는 경우, 해당 수출을 완료하기 위해 미국 정부가 결정해야 할 사항은 없는데, 즉 수출 회사가 단순히 관련 절차를 이행하기만 하면 된다. 당사자들은 자체적인 분석과 결정권에 따라 예외 적용 여부를 판단하고 이에 의거해 거래할 수 있다. 따라서 허가 예외 ENC의 경우, 한번 보고가 이루어지면 미국 정부에 의한 승인이나 검토 없이 수출이 가능하다.

EAR에는 다양한 요구 사항에 따른 18가지 허가 면제의 경우가 있다.²⁷ 비교적 흔히 이용되는 면제에는 다음의 경우들이 있다. 즉 저가 물품 선적(LVS, Shipments of Limited Value), 그룹B 국가로의 선적(GBS, Shipments to Group B countries), 암호화 물품(ENC, Encryption Commodities), 제한 대상인 기술 및 소프트웨어(TSR, Technology and Software under Restriction), 그리고 제한되지 않은 기술 및 소프트웨어(TSU, Technology and Software Unrestricted), 임시 수입, 수출, 재수출, 그리고 동일 국가 내 이전(TMP, Transfers In-Country), 그리고 전략적 교역 허가(STA, Strategic Trade Authorization)이다.²⁸ 허가 면제 전체 리스트를 보려면 EAR 파트 740을 참조해야 하며,

26. 15 C.F.R. § 740.17.

27. *Ibid.* § 740.

28. 18개 EAR 허가 면제에 관한 세부 사항은 15 C.F.R. §§ 740.3 에서 740.21 참조.

해당 허가 면제는 최종 소비자 또는 최종 소비 통제에 따라 통제되는 수출(예를 들어 위에서 언급한 엔티티 리스트 또는 ‘군사 최종 소비자’ 규정에 따르는 경우)에는 일반적으로 적용되지 않는다는 점을 유념해야 한다.

추가적으로, 파트 740.2를 보면 허가 면제가 적용되지 않는 상황에 대한 설명이 있다. 동 상황은 다음을 포함하나 이에 한정되지 않는다. 허가 요청의 중단, 특정한 ECCN으로 관리되는 품목이 ‘유선, 구두, 전자 커뮤니케이션의 도청 또는 관련 소프트웨어’를 위해 사용된다는 사실, 범죄 통제 및 탐지 필요, 미사일 기술 통제 이유, 제재 대상 국가와의 연루, 그리고 대부분의 통제된 ‘미사일 기술’ 또는 ‘600 시리즈’ 품목이 이런 경우이다. 수출 기업들은 자사의 수출이 이들 제한 중 어떤 것에도 적용되지 않도록 유의해야 한다.

D. 일반적인 금지 사항(General Prohibitions)

EAR이 요구하는 사항은 본질적으로 10가지의 ‘일반적인 금지 사항’으로 요약할 수 있는데 이는 수출, 재수출 및 EAR에 적용되는 품목에 대한 활동에 관한 것이다. 이들 금지에 대한 적용 가능성은 해당 품목이 CCL에서 어떻게 분류됐는지에 따른다. 이는 품목의 궁극적인 수출 또는 재수출 목적지, 품목의 궁극적 최종 소비자 및 최종 소비, 관련 활동, 그리고 면제의 적용 여부에 따라 다르다.

일반적인 금지 내용 중 첫 번째 부류는 수출, 재수출 및 (동일 국가 내) 이전에 관한 것으로, 다음 내용을 포함한다.

- 일반적인 금지 1: 허가가 없거나 허가 면제가 없는 경우 BIS의 국가표에 따라 통제되는 국가로의 통제된 CCL상 물품의 수출 또는 재수출 금지
- 일반적인 금지 2: 허가가 없거나 허가 면제가 없는 경우 통제되는 국가로의 최소 기준 이상의 미국 재료(CCL에서 통제하는 재료)를 넘는 양의 외국산 물품 재수출(그리고 해외에서의 수출) 금지, 그리고
- 일반적인 금지 3: 허가가 없거나 허가 면제가 없는 경우 미국 기술 및 소프트웨어의 직접 생산물인 외국산 물품의 재수출(그리고 해외에서의 수출) 금지

일반적인 금지 내용 중 두 번째 부류는 금지된 최종 소비자, 목적지, 그리고 활동에 관한 것으로 다음 내용을 포함한다.

- 일반적인 금지 5: EAR 적용 품목을 금지된 최종 소비자에 대한, 또는 최종 소비 목적으로 허가 없이 수출 및 재수출하는 행위 금지
- 일반적인 금지 6: 허가가 없거나 허가 면제가 없는 경우 엠바고 적용 대상 국가로의 수출 및 재수출 금지
- 일반적인 금지 7: 핵 확산 관련 활동을 위한 미국인의 수출 재수출 및 활동 금지
- 일반적인 금지 8: 특정 금지 국가를 통한 수출 및 재수출 및 이전 금지

마지막으로 일반적인 금지 내용 중 세 번째 부류는 잠재적인 EAR 위반 또는 명령, 조항, 조건 등을 위반한 행위에 대한 인식 하에 취한 행동에 관한 것으로, 다음 내용을 포함한다.

- 일반적인 금지 4: 거부 명령에 따라 금지된 조치에 대한 참여/연루 금지
- 일반적인 금지 9: 수출 허가 또는 허가 면제 조항 및 조건에 위반하는 행위 금지
- 일반적인 금지 10: 불법 수출 물품 사용 등을 비롯한 위반 발생 사실 또는 발생 예정 사실에 대한 인식 하의 참여/연루 행동 금지

일반적인 금지 사항 중 하나라도 위반하는 경우 제재 조치가 있을 수 있다. 일반적인 금지 10의 내용은 불법 수출 물품의 사용을 금지하는 것이어서, 외국인에 대한 손해 배상 청구의 근거가 되는 경우가 많다.

E. 기록 보관 의무

EAR은 또한 기록 보관 의무를 규정하고 있다. 우선, 수출, 재수출 또는 (동일 국가 내) 이전이 있었던 날, 또는 알고 있는 가장 최근의 물품 이동(즉, 불법 이전)이 있었던 날부터 5년 간 다음의 기록을 보관해야 한다.

- EAR 파트 772에서 정의된 수출 통제 문서(허가 및 허가 신청서 포함), 단, SNAP-R 시스템을 통해 전자적으로 BIS에 제출된 문서는 제외

- 메모
- 노트
- 서신
- 계약서
- 입찰 공고문(invitations to bid)
- 회계 장부
- 재무 기록
- 제한적인 무역 관행 또는 보이콧 문서 및 보고서
- 신청이 조치 없이 반려되었다는 BIS의 통지, BIS의 신청 거부 통지, 공산품 분류 또는 BIS에 의한 암호 검토 요구 결과에 대한 BIS의 통지

EAR의 파트 762는 또한 많은 다른 EAR 내 섹션을 참고로 언급하고 있는데, 이는 별도의 기록 보관 의무를 확인하는 내용이다.²⁹ 정확하고 해독 가능하며 내구성이 있다면 사본도 대개 받아들여지지만 기본적으로 원본 기록이 필요하다.³⁰

29. *Ibid.* § 762.2(b).

30. *Ibid.* § 762.5.

제 2 장

허가 신청 절차

A. 신청 방법

수출업자 또는 재수출업자는 산업안전국(BIS)의 SNAP-R(Simplified Network Application Process-Redesign, 단순화된 네트워크 신청 프로세스-리디자인)이라는 시스템을 통해 온라인으로 허가를 신청할 수 있다.³¹ 신청 진행 과정은 다음과 같다.

- 허가 신청 전, 각 신청자는 먼저 온라인으로 등록하고 기업식별번호(CIN : Company Identification Number)를 발급받는다. 그리고 SNAP-R 온라인 등록서를 작성한다.
<https://snapr.bis.doc.gov/registration/Register.do>
- 등록 양식 작성을 마치면, 신청자는 CIN을 발급받고 관리자 권한이 있는 계정을 갖게 된다.
- 등록을 마친 다음, 각 신청자는 SNAP-R에 접근해 허가 신청할 수 있다.
<https://snapr.bis.doc.gov/snapr/>

허가 신청에 관한 모든 소통, 질문 및 요청은 온라인으로 이루어진다. 신청자들은 계류 중인 허가 신청 상태를 SNAP-R상에서 확인할 수 있다. 신청 희망자들은 신속한 신청서 제출을 위해 SNAP-R 계정을 만들어야 한다. 등록 비용은 무료다.

31. 산업안전국, *단순화된 네트워크 신청 절차 - 리디자인 (SNAP-R)*, 주소는 <https://www.bis.doc.gov/index.php/licensing/simplified-network-application-process-redesign-snap-r>.

B. 필요 정보

신청자들이 EAR 허가 신청을 할 때 P/O(Purchase Order)가 필요한 것은 아니지만 거래에 관한 세부 사항은 제공해야 한다. 허가 신청을 위해 신청 예정자들은 다음의 정보를 준비해야 한다.³²

- 신청 관련 질문에 답할 수 있는 담당자 연락처(이름, 전화번호 및 이메일 주소)
- 신청자의 주소 및 고용주 식별번호(EIN : Employer Identification Number)를 포함한 신청자 정보
- BIS를 통해 승인된 허가 내용을 다른 당사자를 지정해 전달하고자 하는 경우에는, 다른 당사자의 정보
- 수출 또는 재수출을 포함한 신청의 종류
- (있는 경우) 기존 허가 번호, 대체 허가 번호, 그리고/또는 수입 인증 국가 및 수입 인증 번호를 포함한 기존 허가 정보
- (이름, 주소 및 전화번호를 포함한) 구매자 정보, 중개 수하인, 최종 수하인, 원래의 최종 수하인 그리고/또는 최종 소비자
- 최종 수하인 그리고/또는 최종 소비자(들)에 의도한 최종 소비에 대한 완전하고 자세한 설명
- 각 품목에 대한 다음을 포함한 수출 정보
 - 수출 통제 분류 번호(ECCN : Export Control Classification Number)
 - 최적수행성능(Adjusted Peak Performance, 신청서에 디지털 컴퓨터 또는 컴퓨터를 포함한 장비가 포함된 경우)
 - 제품/모델 번호
 - CCATS 번호(신청자가 BIS에서 물품에 대한 분류 번호를 수령한 경우)
 - 무역에서 흔히 사용되는 단위 기준으로 수출 또는 재수출할 물량

32. 15 C.F.R. § 748의 부록 1.

- 수출 또는 재수출할 물품의 단위 가격(공정 시장 가격) 및 총 가격
- 제조업체명
- 특정 물품(들)을 식별하는 데에 필요한 세부 사항을 포함한 물품(들)에 대한 기술적 설명
- EAR의 파트 748 조항들의 요구에 따라 제출한 신청 시, 제출한 증빙 서류

C. 정부의 검토

특정한 허가 신청을 검토할 시, BIS는 신청을 증빙하기 위해 제출한 서류와 함께 허가 신청 건 전체에 대해 완전한 분석을 시행한다. 물품 및 최종 소비에 대한 검토는 물론, 거래의 양 당사자의 신뢰성을 살펴보는 한편 가용한 첩보 등도 검토한다.

대개 허가 신청 등록 이후 1주일 내에 BIS는 다음과 같은 조치를 취한다.³³

- 추가 정보가 필요한 경우 신청자에게 연락한다(예를 들어, 허가 신청서가 제대로 완성되지 않은 경우이거나 필수 증빙 서류가 누락된 경우)
- 허가 신청서에 기재된 분류가 맞는지 확인한다.
- 신청서가 완전하게 작성되지 않았거나 허가가 필요 없다는 판단하면 허가 신청서를 반려한다('조치 없이 반려(Returned without Action)' 또는 줄여서 'RWA'로 표기).
- 허가 신청을 승인하거나 신청자에게 허가 신청 불허 방침을 통보한다.
- 신청이 대리권에 의한 것이 아닌 경우, 신청이 필요한 제반 추천서 및 분석 내용과 함께 허가 신청을 모든 기관에 동시에 보낸다.

BIS의 초기 조치에도 불구하고 모든 허가 신청들은 대개 종결되거나(승인, 거부, 또는 RWA), BIS에 허가 신청이 등록된 날부터 90일 이내에 미국 대통령 앞으로 전달된다. 특정한 검토 대상, 특히 미국 국무부, 상무부, 에너지부로 전달이 필요한 경우, 또는 외국 정부와의 협업이 필요한 경우는 다른 경우보다 오랜 시일이 필요할 수 있다. 이에 더해 BIS가 신청자가

33. 15 C.F.R. § 750.4(c)에서는 허가 절차의 타임 프레임을 설명하나 경험상 그것이 엄격하게 준수되지는 않는다.

누락한 정보로 인해 허가 신청을 반려한 경우, 다시 제출한 신청서는 처리 시간 계산 시 처음 신청한 경우로 취급된다. 화웨이와 같이 타깃이 된 엔티티와 연관된 정치적으로 민감한 특정 신청 건의 경우, 절차 처리에 수 개월에서 심지어 1년이 훨씬 넘는 기간이 소요되기도 한다.

D. 허가 신청 승인 가능성을 높이기 위한 방법

SNAP-R을 통해 신청 양식의 필수 정보를 모두 성실히 제공해야 한다는 점 외에 허가 신청의 원활한 승인을 위한 특별한 방법이 있는 것은 아니지만, 일반적으로 ‘설명서’를 모든 허가 신청서에 첨부할 것을 추천한다. 해당 설명서에는 거래의 배경, 모든 관련자, 신청 대상이 되는 모든 물품에 대한 설명을 포함하고, 국가 안보와 외교 정책의 관점에서 왜 해당 신청을 승인해야 하는지에 대한 이유를 기재하면 좋다. 이는 화웨이, 또는 중국, 러시아 및 베네수엘라와 같이 고도로 민감한 대상국으로의 품목 수출과 같이 정치적으로 보다 더 민감한 신청의 경우에 특히 더 추천할 만하다.

특히 특정 물품, 특정 국가, 그리고/또는 특정 최종 소비자에 대해 동 허가 건이 필요하고 신청 승인이 이루어져야 하는 이유를 포함해야 한다. 예를 들어, 한국 기업이 상업적으로 이용 가능한 소프트웨어 또는 하드웨어의 일부를 중국의 ‘군사적 최종 소비’를 위해 수출하고자 하는 경우, 신청자는 ‘군사적 최종 소비’ 규정에 따라 중국군이 미국 기술을 군사 목적으로 이용하기 위해 이에 접근하는 것은 금지되는 점을 고려한다. 그러므로 신청자는 신청 승인을 위해, 관련 소프트웨어 또는 하드웨어가 이미 중국에서 쉽게 구할 수 있는 상태이고, 해당 소프트웨어 또는 하드웨어가 군사적인 목적으로 사용되는 것이 아님(단, 그것이 사실인 경우)을 설명해야 한다. 또한 이를 테면, 화웨이에 대한 미국 정부의 관심은 주로 화웨이가 중국 이외의 지역에서 네트워크 및 통신 기술을 널리 펼칠 수 있는 능력을 제한하는 데 있다. 그러므로 네트워킹 관련 물품에 대한 신청은 다른 물품에 대한 신청(예를 들면, 화웨이 폰을 위한 게이밍gaming 플랫폼)의 경우보다 승인받을 가능성이 훨씬 낮다. 따라서 신청 시에 화웨이를 위한 해당 거래가 미국 정부의 핵심적 우려와는 무관하다는 점을 증명하는 방안을 고려할 수 있다.

제 3 장

산업안보국(BIS)의 현장 조사 대비

EAR 파트 762에 따르면 개인과 조직들은 미국으로의 수출 또는 재수출 활동이 있었던 마지막 날부터 5년간 수출 기록을 보관해야 한다.³⁴ 또한 BIS, 미국 관세청, 기타 정부 기관의 조사 및 복사 요청이 있는 경우 기록을 제공할 의무가 있다.³⁵ 상무부는 조사 요청에 대한 자발적 협조를 독려하고, 미국 내에 있는 사람들에게는 출두해 증언하라는 출두 명령을 내릴 수도 있으며 기록 제출을 요구할 수도 있다.³⁶ 이러한 조사는 해당 기업이 전형적으로 EAR 허가에 따라 EAR이 적용되는 물품의 수령자인 경우, 또는 기업들이 EAR의 ‘증명된 최종 소비자’(VEU, Verified End User) 프로그램, 즉 외국 기업들에게 고도로 통제되는 품목 수령에 대해 보다 유리한 허가 지위를 부여하는 제도와 같이 보다 폭넓은 승인을 얻고자 하는 경우에 행해진다.³⁷

A. 준법 정책 및 프로그램

EAR이 규제하는 활동에 들어가기 전에, 그리고 현장 조사가 이루어지기 전에는 회사에서 수출 준법 프로그램이나 절차를 확실히 마련해 둘 필요가 있다. BIS는 <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/pdfs/1641-ecp/file>에서 준법 프로그램의 모범 모델을 제공하고 있다. EAR 이행 가이드라인, 15 C.F.R. 파트 766의 부록1에도 ‘해당 기업에 준법 프로그램이 있으면 제재 조치 대상인 위반 행위에 대한 처벌 수위 결정에 감경 요소가 된다.’고 기재하고 있다. 다른 고려 요소로는 은폐 사실이 있었는지, 해당 위반 행위가 반복적인 패턴

34. 해당 수출 또는 재수출 활동의 최근 일자에는 다음이 포함된다. (1) 알려진 재수출, 교차선적 또는 수출품의 전환, (2) 공식 서면에 의한 것인지 기타 수단에 의한 것인지를 불문하고 거래가 종료된 날, 또는 (3) 제한적인 무역 관행 또는 보이콧과 관련한 거래에 관한 기록이 있는 경우, 규제 대상자가 보이콧 관련 요청 또는 요구를 받은 날. 15 C.F.R. § 762.6(a) 참조

35. *Ibid.* § 762.2(a).

36. *Ibid.*

37. 15 C.F.R. § 748.15 참조.

으로 이루어졌는지, 경영진의 연루 여부, 연루되었다면 어떻게 연루되었는지 등이다. 그리고 이 모든 요소들은 효과적인 준법 프로그램이 회사에 있었는지 여부에 영향을 받는다.

무엇보다 준법 프로그램은 동 매뉴얼 챕터1의 섹션 E에서 규정하는 요구 사항에 맞추어 기록 보존 시스템을 포함해야 하고, 회사 준법 감시인에게 잠재적인 EAR 위반 사례를 보고하도록 하는 명확한 정책도 있어야 한다. 준법 프로그램은 경영진의 수출 준법을 위한 노력을 충실히 반영해야 하며, 회사 최고 경영진의 승인을 받아야 한다. 그리고 아래에 보다 자세하게 다루겠지만, 특정 예외가 있기는 하나 위반 사례에 대한 BIS 보고는 의무 사항이 아니다.

BIS는 기업들이 잠재적 수출 준법 리스크에 대한 문제 소지가 있는 대상과 거래 시에 '경고등(위험 징후)'이 켜지는지를 잘 지켜보아야 한다고 강조했다. 그러한 '경고등'의 예는 다음과 같다.

- 고객 또는 고객의 주소가 상무부의 [BIS의] 부적격자 목록(List of Denied Persons)과 유사한 경우
- 고객 또는 구매 대행자가 품목의 최종 소비에 대한 정보 제공을 꺼릴 때
- 상품의 성능이 구매자의 사업 내용과 부합하지 않을 때(예를 들면, 영세한 제과점에서 고성능 컴퓨터를 주문하는 경우)
- 발주된 품목이 선적 대상국의 기술 수준과 맞지 않을 때(예를 들면, 전자 산업이 없는 국가에 반도체 제조 장비가 선적되는 경우)
- 판매 조건으로 볼 때 자금 조달이 필요한 상황임에도, 고객이 매우 비싼 품목의 가격을 현금으로 기꺼이 지불하고자 할 때
- 고객의 비즈니스 경험이 거의 없거나 전무할 때
- 고객이 상품의 성능이나 세부 사항에 익숙하지 않으면서도 그 상품을 원할 때
- 고객이 일상적인 설치, 훈련 또는 유지 서비스를 거부할 때
- 배달 일자가 모호하거나 배달 도중 목적지로 가는 경로를 벗어나도록 계획돼 있을 때
- 화물 운송 회사가 상품의 최종 목적지로 돼 있을 때

- 선적 경로가 상품과 목적지에 비추어 이례적인 것일 때
- 설명한 선적 방법 또는 목적지와 포장에 불일치할 때
- 질문을 받았을 때 구매자가 대답을 회피하고 구매 상품의 사용 목적이 국내 사용, 수출 또는 재수출 중 어느 것인지 물었을 때 특히 모호하게 대답하는 경우

상기 정황(경고등)이 발견된다고 해서 무조건 거래를 포기할 필요는 없다. 기업들은 필요 시 거래 상대방과의 서면 계약에 ‘미국 수출통제법 및 기타 관련 보증 내용(화웨이 상품에 해당 품목이 합체되도록 하지 않겠다는 보증 등)을 준수하겠다.’는 내용을 포함하는 방안도 고려할 수 있다. 미국 정부는 또한 기업들이 수출 통제 절차 준수와 관련해 리스크에 기반한 접근법을 취하기를 기대하는데, 그러한 경우에는 보증 및 계약상에 조항을 마련하는 것만으로는 충분하지 않다. 회사들은 준법 리스크를 증가시키는 상대방에 대한 독립적인 평가 및 실사 실시를 고려해야 한다. 예를 들어, 화웨이에 납품하는 것으로 알려진 회사에 물건을 판매하는 경우에는, 해당 회사에 수출된 우리 제품을 화웨이에 공급하지 않겠다는 서면 약속을 요청하는 것만으로는 충분하지 않다. 수출업자는 규정 준수를 확실히 해 두기 위해 해당 회사를 어떻게 독립적으로 평가할 것인지 또는 감사할 것인지에 대해서도 고려해야 한다.

마지막으로, 준법 프로그램은 개별 직원들로 하여금 위반 의심 사례를 보고하도록 독려하고, 잠재적 위반사례 발생이 의심될 때 ‘중단, 통지 그리고 문서화’와 같은 대응 프로토콜을 포함해야 한다.

중단

거래를 즉시 중단하는 경우. 예를 들어

- 발주서(P/O)가 제출된 경우, 해당 발주 건을 보류하고
- 물품이 선적은 되었으나 도달하지 않은 경우, 선적을 중단하는 게 가능한지 판단하고,
- 물품이 도달한 경우, 유통하거나 사용하지 않고,
- 물품이 사용 중인 경우, 사용을 중단하고 이를 안전한 장소에 보관한다(격리).

통지

의심 거래가 중단된 경우, 직원들은 관련 회사의 준법 담당자에게 이를 통지해야 한다.

서류

거래와 관련한 서류를 비치하고 보관한다. 여기에는 다음이 포함되나 이것으로 한정하지는 않는다.

- 발주서(P/O)/하도급(하청) 계약서
- 선적 문서
- 포장 전표(Packing Slip)와 같은 수령 문서
- 관련 서신
- 당사자 검사 결과(Party Screening Results)
- 관련한 교육/훈련 보고서

잠재적 위반 사항이 보고되면, 관련 준법 담당자는 해당 사실을 보고한 담당자 및 경영진과 함께 협력해 실제로 위반했는지를 조사하고 판단해야 한다. 관련 조사는 문서 검토, 담당자 인터뷰, 판매자 그리고/또는 고객과의 미팅을 포함할 수 있다.

B. 현장 조사 수검을 위한 준비

BIS 또는 다른 미국 정부 부처에 의한 조사는 예고 없이 이루어질 수 있으므로, 회사들은 준수 계획, 기록 보존 시스템 그리고 조사 대응 계획 개발을 위해 상당한 자원을 투입할 필요가 있다.

먼저, 기업들은 EAR상의 기록 보존에 대한 요구 사항을 고려해 기록 관리 시스템을 마련해야 한다. 이를 위해 기업(이하에서 기타 각종 조직 포함)들은 먼저 수출과 재수출에 관한 일상적 활동을 분석하고 보관해야 할 문서들의 리스트를 작성할 수 있다. 유지가 필요한 기록의 종류는 해당 기업 활동의 본질, 그리고 어떻게 EAR 하에서 통제되는지에 따라 좌우

된다. 그러한 정보와 더불어 기업들은 기록 보존 관련 책임 및 기준에 관한 절차를 마련해야 한다. 회사 내 각 사업 단위, 기록 관리, 시스템 관리, 그리고 다른 여타 분야 인력들 간 책임 소재가 분명하게 나누어져 있어야 한다. 기업은 또한 기록 관리 절차에 대한 전반적인 관리가 이루어지도록 노력해야 한다.

적절한 기록 보관 절차 및 시스템을 확립한 후, 기업들은 조사 시에 효율적인 검색과 추출이 가능하도록 필요한 기록을 확보해 올바르게 파일화해야 한다. 가능하다면, 기업들은 정보기술 개발의 디자인 또는 기획 초기 단계에 기록 보관 요구 사항을 고려한다. 새로운, 또는 기존 시스템을 업그레이드 구축할 때, 회사들은 모든 적절한 기록이 수집되도록 하고 기술상의 변화 때문에 기록이 쓸모없어지지 않도록 관리 방안을 고려한다. 마지막으로 기업들은 주기적으로 불의의 오류 또는 시스템 충돌이 있을 경우 시스템과 서버가 회복될 수 있도록 중요한 데이터를 다른 곳에 백업해 놓는다.

다음으로, 조사에 대비해 회사는 위기관리팀(CMT, Crisis Management Team)을 조직하고 대응 계획을 개발해야 한다. 기업과 직원들이 이를 통해 불시의 정부 검사에 신속하게 대응할 수 있게 하기 위함이다. 위기관리팀은 현장 책임자 및 현장 부책임자를 포함한 핵심 직원들로 구성해 조사 발생 시에 대응하도록 한다. 여러 책임이 있지만 우선 현장 책임자들은 외부 자문 인력이 도착할 때까지 정부 변호사들과 관계자들과 연락을 취한다. 위기관리팀의 다른 팀원으로는 언론 질문 또는 발표에 대응할 수 있는 홍보 인력, 전자 정보의 위치를 파악할 수 있는 정보 기술 인력, 그리고 기록의 위치에 대해 잘 알고 이를 찾고 관련 기록을 할 수 있는 기타 핵심 멤버가 있어야 한다. 각 기업은 외부 자문 인력과 협업해 자세한 대응 계획을 수립하며, 이 계획에는 조사 전후에 취할 구체적인 조치 내용을 포함해야 한다.

제 4 장

잠재적 EAR 위반 사례에 대한 대처

A. EAR 위반

위에서 설명한 일반적인 금지 사항(제1장 제D조)을 위반하는 경우 제재 조치를 취한다. 추가로, 다음의 조치 또한 EAR 위반에 해당한다.³⁸

- 수출되었거나 수출될 EAR 적용 물품에 대한 위반 사실 또는 위반 가능성을 알면서 발주·구매·제거·은폐·보관·사용·판매·대여·폐기·이전·운반·파이낸싱·전달 또는 다른 서비스(용역)를 제공하는 행위
- 금지된 행위에 가담하거나 수출통제개혁법(ECRA), EAR 또는 여타 명령, 그에 따른 허가 또는 승인에 의해 요구되는 행위를 하지 않은 경우
- 위반을 야기, 보조, 자문, 명령, 허락 또는 교사하거나 요구되는 행위를 하지 않은 경우
- EAR 또는 다른 명령, 허가 또는 승인 내용 위반을 권유하거나 시도하는 행위
- EAR, 명령, 허가 또는 기타 승인 내용을 위반하거나 요구되는 행위를 하지 않는 결과를 초래하는 방법 또는 그렇게 할 목적으로 한 명 이상의 사람과 모의하는 행위
- 국가 안보 또는 대외 정책 목적으로 통제되는 물품을 불법 수출 목적이나, 불법 수출 될 것을 알면서 소지하는 행위
- 수출, 재수출 또는 다른 관련 활동에 영향을 줄 목적으로 조사 중 또는 준비, 제출, 사용 또는 유지 중 중요한 사실에 대한 허위 발표 또는 인증 또는 위계 또는 은폐해 사실을 잘못 해석하거나 은폐하는 행위
- EAR 적용 거래 시 EAR, 기타 명령, 허가 또는 다른 승인 조항을 회피하는 행위

38. *Ibid.* § 764.3.

- EAR, 기타 명령, 허가 또는 다른 승인 조항에 의한 보고 및 기록 유지 요구 사항을 준수하지 못하는 행위
- EAR에 의해 특별히 승인되었거나 BIS의 서면에 의해 예외 처리된 경우 외에 허가, 승인, 수출 통제 문서 또는 EAR에 따른 명령을 변경하는 행위
- BIS에 따른 명령의 내용과 배치되는 행동을 하는 경우

B. 자발적인 자기 공시(Voluntary Self-Disclosures)

상무부는 EAR 위반 의심 사례를 공시하도록 BIS 수출집행부(OEE : Office of Export Enforcement, 이하 OEE)에 강력하게 권고한다. 기업의 '자발적인 자기 공시(VSD)'는 행정 조치가 취해지는 경우, OEE가 어떠한 조치를 취할지를 결정할 때 그 수위를 경감하도록 할 수 있고, 해당 사건에서 다른 모든 요소들과 함께 고려된다. 반면, 기업들은 원치 않는 질문이나 미국 정부의 검열을 피하기 위해 위반 사실을 공시하지 않는 선택을 할 수도 있다. 이외에도 조직의 리스크 감수 정도에 따라 회사는 외부 법률 전문가의 조언을 듣는 방법을 선호할 수도 있다.

어떤 기업(이나 조직)이 위반 사실을 자발적으로 공시하는 경우 해당 회사는 위반 사실이 발견된 즉시 가능한 한 빨리 이를 OEE에 알리고 위반이 의심된 사례의 모든 수출 관련 거래를 철저히 검토해야 한다. 최초의 통지는 서면으로 하며 이에는 공시자의 이름 및 주장된 위반 내용에 대한 간단한 설명을 포함해야 한다. 전체적인 의미에서의 공시가 이루어지는 경우에만 자발적인 자기 공시가 최초 통지 시에 이루어진 것으로 인정될 수 있다.

최초 통지 후에는 위반 의심 대상에 대한 모든 수출 관련 사항을 철저히 검토해야 한다. 검토 시 가능하면 최초 통지 시부터 5년 이전의 기록까지 모두 포함해야 한다. 검토 완료 후, OEE는 위반 의심 내용에 대한 충분한 설명이 포함된 문서를 제공받아야 하고, 이에 따라 위반의 본질과 정도를 평가할 수 있으며 그 문서는 아래의 사항들을 포함해야 한다.

- 관련 위반의 종류, 예를 들어 요구되는 허가 없이 이루어진 선적 또는 수출 권한이 부인된 당사자와의 거래
- 위반 발생 시기와 방법에 대한 설명
- 국내외를 불문하고 위반에 이르기까지 연루된 활동을 한 모든 개인 및 조직의 정체와 주소
- 허가 번호
- 거래된 물품에 대한 상세한 개념 설명(description), 수량, 달러화 기준 가치 및 ECCN 또는 관련 물품에 대한 다른 분류 번호
- 감경 고려 요소에 대한 설명
- 이행된 검토 내용의 본질 및 미래의 위반 발생 가능성 최소화를 위해 취한 조치

문서 제출 후에는 아래 내용을 포함하는 설명 및 증빙 문서를 제출해야 한다.

- 허가(증), 허가 신청서, 수입 증명서 및 최종 소비자 진술서 등 허가 문서
- 자동통관환경 전자수출정보(ACE EEI : Automated Commercial Environment, Electronic Export Information) 기록, 항공 화물 운송장 및 선하 증권 등 선적 서류
- 관련 서신, 팩스, 텔렉스 및 기타 서면 및 구두 커뮤니케이션에 대한 증빙, 내부 메모, 발주서, 송장, 신용장 및 브로슈어 등 기타 문서

설명 문서에 첨부되지 않은 기타 관련 문서는 OEE가 요청할 때까지, 또는 공시 정보에 대한 최종 결정이 이루어질 때까지 공시 담당자가 보관한다. 최종 결정 후 문서들은 EAR 파트 762에 따른 기록 보존 규정에 따라 보관한다.

C. 제재 조치에 따른 잠재적 결과

EAR 위반자는 엄중한 형사, 행정 및 민사상 처벌을 받을 수 있다.

OEE는 명백한 위반 사례를 조사하고 조사 결과에 근거한 적절한 조치를 취할 책임이 있다. OEE는 조사 시 사례별 접근법을 활용하고 결과적인 조치 또는 대응은 개별 사례에 관한 사실 관계와 여건에 근거해 취한다. 명백한 위반 사례에 대해 OEE가 취하는 전형적인 조사 후 대응 방법은 다음 7가지가 있다. **첫째**, 위반이 발생하지 않은 경우, OEE는 취할 조치가 없다는 내용의 서신을 보낸다. **둘째**, 위반은 있었으나 민사상 조치가 발령되지 않는 경우에는 경고 및 EAR 준수를 독려하는 내용의 서신을 보낸다. **셋째**, OEE는 위반 사례를 확인한 결과 민사상 과태료 또는 기타 행정상 제재가 필요하다고 결론 내릴 수 있다. 그러한 경우, OEE는 행정 집행 절차를 시작하고 고발장을 보낸다. **관련해, 그리고 넷째로**, OEE는 민사상의 과태료 부과만 한다는 결론을 내릴 수도 있다.

다섯째, 적절한 경우 OEE는 명백한 위반에 대하여 형사 처벌을 구하고 해당 사안을 미국 법무부에 송치할 수 있다. **여섯째**, OEE는 허가 중지 또는 취소, 수출권 박탈, BIS 앞에서의 영업 금지, 훈련/감사 요구 사항에 대한 이행 요청 등 기타 행정상 제재를 취할 수 있다. 여기에는 해당 주체를 EAR에 근거해 '부적격자 목록' 또는 '엔티티 목록'에 포함시키는 조치가 포함되는데, 해당 조치가 이루어지면 EAR이 적용되는 물품과 관련 회사의 거래를 제한하거나 금지한다. 따라서 부과된 조치에 따라 공급망 그리고/또는 고객 접근 등에 심대한 부정적 영향을 초래할 수 있다. **마지막 일곱 번째로**, OEE는 최종 판단 및 BIS 명령에 따라 집행유예 기간 동안 민사상 과태료 납부를 중지하거나 유예할 수 있다.³⁹

EAR 위반에 따른 형사 처벌 최고형은 징역 20년 ⁴⁰ 및 위반 건당 벌금 100만 달러⁴¹, 그리고 미국 정부와의 계약 중단 또는 금지 조치다.⁴² EAR 위반에 따른 제재에는 수출 권한 박탈도 포함한다.⁴³ EAR 하에서 수출 권한 박탈은 혐의 인정에 따라 자동으로 발생하는 결과는 아니고, '예외적인 상황'만 아니라면 해당 제재를 받게 될 개인이나 조직에 서면

39. 15 C.F.R. § 766.

40. *National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019*, H.R. 5515, § 1760(b).

41. *Ibid.*; 15 C.F.R. § 764.3(b).

42. FAR §§ 9.403, 9.406-2(b)(iv); 15 C.F.R. § 764.3(c)2(ii) (제재 기관의 잠재적인 교차-자격중지에 관한 설명) 참조.

43. 15 C.F.R. § 766.25; *Ibid.* § 764.3(a)(2).

해명 제출 기회를 부여한다. BIS는 수출 권한 박탈 결정에 앞서 감경 요소들을 고려한다.⁴⁴ 그러나 수출 권한 박탈이 제재 조치로 부과되면 최대 10년까지 그 효력이 발생할 수 있다.⁴⁵

미국 이외 국가 기업들의 경우 흔한 제재 조치는 엔티티 리스트 등재인데, 그 효과는 해당 기업으로 EAR 적용 물품의 허가 없는 수출을 금지한다는 것이다. 한번 등재되면 리스트에서 삭제되기 매우 어려운데, 불복 절차가 있기는 하지만 미국 이외 국가의 기업이 미국에서 완전하고 개방된 절차에 따른 권리를 충분히 확보하기는 어렵다.

D. 처벌

위에서 다룬 내용 외에도, EAR 수출 위반 제재 조치는 매우 가혹한 점들이 있다. ECRA(수출통제개혁법)에 의해, 위반 건에 대해 부과될 수 있는 민사 제재는 과태료 30만 달러 또는 위반 관련 거래 금액의 두 배까지이며 형사 처벌도 이루어질 수 있다. 중요한 것은, 미국 정부는 ‘위반’을 여러 가지 다른 방법(선적, 물품, 일자)으로 계산할 수 있기 때문에 상황에 따라 제재 금액이 변동될 수 있고 정부에 자발적으로 협조해 사건이 종결되도록 압박을 가할 수 있다는 점이다.

금전적 제재에 더해, 위반의 결과 아래와 같은 다른 유형의 제재를 부과할 수 있다.

- 수출 권한의 불허, 중지 또는 제한
- 회사가 수출 또는 재수출 권한에 따라 할 수 있는 거래에 대한 제한
- 불법 수출이 이루어졌거나 이루어질 예정이었던 물품의 압류 또는 압수
- ITAR(미국 국제무기거래규정, International Traffic in Arms Regulations) 수출 권한 중지를 포함한 다른 부문에서의 자격 중지
- 미국 정부와의 계약 건의 추가적 수주 금지 또는 중지
- 상당한 대외 이미지 훼손

44. *Ibid.* § 766.25(b).

45. *Ibid.* § 766.25(d).

민사적 제재에 더해, 형사적 위반은 의도를 가지고 고의로 행한 경우에 인정한다. ‘고의’의 정의는 EAR에 정의돼 있는데, 실제로 그러한 여건이 존재함을 알고 있었던 경우 외에도 문제 발생 가능성이 높다는 점을 알고 있었던 경우, 문제 존재 가능성 또는 미래의 문제 발생 가능성을 인식한 경우까지 포함한다. 그러한 인식은 한 사람에게 알려진 사실에 대한 고의적인 무시의 정황으로부터 추론할 수도 있고 한 사람의 사실에 대한 고의적 회피에서 추론할 수도 있다.

ECRA 위반을 구성하는 행위는 다른 법률에 의해서도 처벌할 수 있는데, 여기에는 18 U.S.Code § 371 (음모), 18 U.S.Code § 1001 (위증), 18 U.S.Code §§ 1341, 1343, 그리고 1346 (유무선 수단을 통한 사기), and 18 U.S.Code §§ 1956 and 1957 (자금 세탁)을 포함한다.

부 록

미국의 대 화웨이 제재

2019년 5월 15일, 화웨이 및 화웨이의 기존 계열사들이 엔티티 리스트에 등재됐다. 이후 약 60개 정도의 화웨이 계열사가 추가됐고, 그 수치는 현재 150개에 이른다. 이는 화웨이의 공급망에 심대한 지장을 초래한 것은 물론이고 미국 내외 기업들이 화웨이와의 사업을 지속하기가 어려워졌다. 그러나 엔티티 리스트는 리스트에 등재된 개별 법인에만 적용하고 수출 제한 역시 화웨이에 수출되는 EAR 적용 물품에만 적용한다. 리스트에 등재된 기업들의 계열사나 자회사들에 엔티티 리스트 제한을 자동 적용하는 것은 아니다(단, 상무부는 해당 관계사가 EAR 적용 물품을 등재된 자신의 관계사에 이전할 수 있는 만큼, 엔티티 리스트 등재 법인의 관계사와 거래하는 것을 높은 준법 리스크로 간주한다고 경고한 사실은 있다).⁴⁶ 본 매뉴얼 챕터1의 섹션A.2에서 설명했듯이 화웨이가 EAR에 따라 여러 가지 구체적이고 광범위한 통제를 받고 있기는 하지만 EAR 적용 대상이 아닌 물품 이전은 마찬가지로 제한하지 않는다.

더불어 화웨이는 현재 해외자산통제국(OFAC : Office of Foreign Assets Control : 재무적 제재 블랙리스트로 이에 등재된 주체들과는 미국 기업들이 어떠한 거래도 할 수 없음)이 관리하는 SDN 리스트에는 등재돼 있지 않다. 그러나 최근의 ‘클린 네트워크’ 이니셔티브의 공개 성명(아래)을 보면, 미국 국무부는 화웨이를 ‘인권 유린자’로 표현하고 있다.

- ..신뢰할 수 없는 중화인민공화국(PRC) 스마트폰 제조업체가 신뢰할 수 없는 앱을 앱스토어에 미리 설치하거나 다운로드 하도록 만드는 일을 방지하기 위해서다.

46. BIS FAQs 참조, https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/faqs#faq_134 ('자회사, 모회사, 그리고 자매회사는 등재된 회사와 별도의 법인이다. 그러므로 등재된 회사에 부과되는 허가 및 여타 의무가 리스트에 등재되지 않은 자회사, 모회사, 자매회사 또는 기타 별도 법인격을 가진 관계 회사에 적용되지는 않는다. 그러나 만약, 그러한 회사 또는 관계없는 회사가 매개자, 대리자, 또는 페이퍼컴퍼니 자격으로 등재된 회사에 허용되지 않을 거래를 도모하는 활동을 하는 경우에, 해당 회사는 EAR 섹션 764.2(b) 일반 조항 10(위반을 초래, 조력, 또는 교사)과 764.2의 다른 하위 섹션의 내용을 위반한 것으로 볼 수 있다. EAR 적용 품목이 등재된 회사의 자회사, 자매회사, 모회사 또는 다른 관계사를 목적으로 한다는 사실을 알면서 이를 수출, 재수출 또는 이전하는 자는 추가적인 실사 작업을 거처기를 권장한다[.]')

화웨이는 ‘감시 국가’인 중국의 도구로써, 미국 및 다른 외국 주요 기업의 혁신과 명성을 부당하게 이용하고 있다. *이들 기업들이 인권 유린자와 협업하는 꼴이 되지 않기 위해서는 화웨이의 앱스토어에서 자신들의 앱을 삭제해야 한다.*⁴⁷

미 정부의 이러한 표현을 감안하면, 미국이 중국 내 다른 기업들을 추가 타깃으로 SDN 리스트 등재를 고려하고 있을 가능성도 있다. 미국이 화웨이 같은 회사를 SDN 리스트에 등재하는 경우, 미-중 무역 갈등이 극도로 높은 수준의 분쟁으로 비화할 수 있으며, 현재 정치 환경에서는 전혀 가능성 없는 일도 아니다. 미 국무부가 화웨이를 ‘인권 유린자’라고 부른 것은 SDN 등재의 전조일 수 있다.

47. <https://www.state.gov/the-clean-network/#:~:text=The%20Clean%20Network%20program%20is,as%20the%20Chinese%20Communist%20Party.>

contents

Chapter 1 Overview of the Export Administration Regulations (“EAR”)	38
A. Determination of Whether a Given Item is Subject to the EAR	40
1. De Minimis Rule	41
2. Foreign Direct Product Rule	45
B. Determining Whether a License is Needed for a Particular Item	49
1. Classification	49
2. Destination	50
3. End Use/End User Controls – Generally	52
4. Military End User Rule	53
C. License Exceptions	55
D. General Prohibitions	56
E. Recordkeeping Requirements	58
Chapter 2 Procedures for License Applications	59
A. How to Apply	59
B. What Information is Required	60
C. Government Review	61
D. Increasing Likelihood that Applications Will Be Granted	62
Chapter 3 Preparation for On-Site Inspection by Bureau of Industry and Security (“BIS”) ...	64
A. Compliance Policies and Programs	65
B. Preparing for an Inspection	68
Chapter 4 Addressing Potential Violations of the EAR	70
A. EAR Violations	70
B. Voluntary Self-Disclosures	71
C. Potential Outcomes Resulting from Enforcement Actions	73
D. Penalties	75
Appendix U.S. Sanctions Against Huawei	77

Chapter 1

Overview of the Export Administration Regulations (“EAR”)

The EAR was originally implemented under the Export Administration Act of 1979 (“EAA”). In the year 2000, the EAA lapsed and Congress failed to timely renew the law. In order to maintain existing export controls, the President reissued the EAR under the International Emergency Economic Powers Act (“IEEPA”) under the emergency authorities of that law. In 2018, after eighteen years, the EAR was formally reauthorized by Congress under the Export Control Reform Act (“ECRA”). Today, ECRA is the statutory basis on which the EAR rests, although practically the EAR has not changed significantly in form or operation since the original passage of the EAA.

The EAR regulates the export, re-export, and transfer in-country of any “items” that are “subject to the EAR.” An “export” under the EAR is a shipment out of the United States or a release of controlled technology to a non-U.S. persons wherever located.¹ A “re-export” is a shipment or release between two non-U.S. countries or non-U.S. persons.² A “transfer (in-country)” is a shipment or release between two parties in the same country.³ Throughout this manual, we generally refer to “exports, re-exports, and in-country transfers” of items when we refer to transactions that may require a license under the EAR or would otherwise be restricted. For example, shipping an item subject to the EAR from one company in China to another company in China is an in-country transfer that could require a U.S. government license, even though it takes

1. 15 C.F.R. Part 734.

2. *Id.*

3. *Id.*

place only in China. Sometimes in this manual, for shorthand, we refer only to “exports” or “exporters.” Wherever we do so, we do not mean to imply that the restrictions apply only to “exports.” All EAR restrictions and rule apply equally to “exports,” “re-exports,” and “transfers (in-country).”

The term “item” under the regulations refers to “commodities, software, and technology.”⁴

- A “commodity” is “[a]ny article, material, or supply except technology and software.” “Technology” is any “[i]nformation necessary for the “development,” “production,” “use,” operation, installation, maintenance, repair, overhaul, or refurbishing ... of an item.”⁵
- “Software” generally includes any machine readable object code, as well as, in some cases, source code, although the regulations sometimes treat source code as a form of “technology.”⁶
- “Technology” may be in any tangible or intangible form, such as written or oral communications, blueprints, drawings, photographs, plans, diagrams, models, formulae, tables, engineering designs and specifications, computer-aided design files, manuals or documentation, electronic media or information revealed through visual inspection of an item.
- Software and technology that are “published,” that is, available without restriction for free to the general public, are not subject to the EAR (except that the public Internet location of open source encryption software must be sent to the U.S. government before it is considered “published”).⁷

4. 15 C.F.R. § 772.

5. *Id.*

6. *Id.*

7. Under 15 C.F.R. § 742.15, publicly available encryption source code is not subject to EAR controls if the developer notifies the U.S. government “via email of the Internet location (e.g., URL or Internet address)

A. Determination of Whether a Given Item is Subject to the EAR

The following items are subject to the EAR:

- (1) All items in the United States, including in a U.S. Foreign Trade Zone or moving in transit through the United States from one foreign country to another, including where U.S.-based facilities are used to store or transmit software to a party outside the U.S. (*e.g.*, if a U.S. data center is used, everything that passes through the US data center is subject to the EAR);
- (2) All U.S. origin items wherever located;
- (3) Foreign-made commodities that incorporate controlled U.S.-origin commodities, foreign-made commodities that are ‘bundled’ with controlled U.S.-origin software, foreign-made software that is commingled with controlled U.S.-origin software, and foreign-made technology that is commingled with controlled U.S.-origin technology:
 - In any quantity, for certain items, and
 - In quantities exceeding the *de minimis* levels, for most other items;
- (4) Certain foreign-made direct products of U.S.-origin technology or software. The term “direct product” means the immediate product (including processes and services) produced directly by the use of technology or software; and
- (5) Certain commodities produced by any plant or major component of a plant located outside the United States that is a direct product of U.S.-origin technology or software.⁸

of the publicly available encryption source code . . . or provide each of them a copy of the publicly available encryption source code. . . . In all instances, submit the notification or copy to crypt@bis.doc.gov and to enc@nsa.gov”. Usually, the original developer notifies the U.S. government of the software to release it from control, but any party can send the government the internet location where the software is available to ensure it is treated as “open source” under the EAR.

8. 15 C.F.R. § 734.3(a).

There is nuance to the application of these standards, but generally the EAR covers everything produced in the United States and everything that has transited through the United States. This coverage is reflected in items (1) and (2) above.

The EAR does not cover all goods, software, or technology produced outside of the United States. That is true even where U.S. content is incorporated into the goods, software, or technology (for example, where U.S. made components are installed into non-U.S. made equipment), or U.S. software or technology is used to make the goods (for example, where U.S. intellectual property is used to make hardware outside the U.S.). Rather, non-U.S. producers and developers must assess what materials and components in the case of goods, or U.S. code or technical information in the case of software or technology, is incorporated into their non-U.S. produced items. This approach is known as the *de minimis* rule (item (3) above). Separately, under the **foreign direct product rule** (items (4) to (5) above), non-U.S. producers must consider whether and what U.S. software or technology was used in the production or development of the non-U.S. item (but not incorporated into it). Altogether, these analyses inform what non-U.S. items are subject to the EAR.

1. De Minimis Rule

If an item is produced outside the United States, then the first analysis about whether the item is subject to the EAR is based on whether the item “incorporates” or is “bundled with” controlled U.S. content above what is called the “de minimis” level. The EAR explains when an item “incorporates” or is “bundled” with U.S. controlled content:

- U.S.-origin controlled content is considered “incorporated” for de minimis purposes if the U.S.-origin controlled item is: Essential to the functioning

of the foreign equipment; customarily included in sales of the foreign equipment; and re-exported with the foreign produced item. U.S.-origin software may be ‘bundled’ with foreign produced commodities; [‘bundled’ means software that is re-exported together with the item and is configured for the item, but is not necessarily physically integrated into the item]. For purposes of determining *de minimis* levels, technology and source code used to design or produce foreign-made commodities or software (but are not incorporated into the commodities or software itself) are not considered to be incorporated into such foreign-made commodities or software.⁹

Generally, the *de minimis* calculation must be performed separately for technology, software, and hardware. However, in 2008, BIS revised the *de minimis* rules, in response to the way systems and software are being developed and delivered to customers. Under the new rule, the value of “bundled” U.S.-origin software are to be compared with the value of the hardware. However, this exception only applies to software controlled at a low level (“EAR99”) or “Anti-Terrorism.” Thus, it applies to most commercial grade software but not software customized for more sensitive applications. For more highly controlled software, the value of the software and hardware must be assessed separately.

If an item contains less than the *de minimis* amount of controlled U.S. content relative to the total value of the item, then the item would *not* be subject to the EAR.¹⁰ The *de minimis* threshold is defined as follows:

- For exports to Cuba, Iran, North Korea, Sudan, and Syria, the *de minimis* threshold is 10% U.S. origin content.¹¹

9. Supplement No. 2 to 15 C.F.R. § 734.

10. 15 C.F.R. § 734.3(a)(3)(ii).

11. *Id.* § 734.4(c).

- For exports to all other countries, including Korea, the threshold is 25%.¹²
- Some items are so sensitive that there is no *de minimis* level, meaning that if the item is incorporated within the non-U.S. made item, then the non-U.S. made item is automatically “subject to the EAR.”

The methodology of determining the value is outlined below:

- The amount of controlled U.S.-origin content in an item is determined by valuing all U.S.-origin content of the item that would require an export license for the destination country that is incorporated into the final product.
- First, the exporter should determine the Export Control Classification Numbers (“ECCN”) for all of the U.S.-origin content, and determine which of those ECCNs would require a license if they were to be re-exported to the destination country.
- The U.S.-origin content that would require a license for transfer to the country of destination (otherwise termed “controlled U.S.-origin content”) is then valued at fair market value, which for unaffiliated companies is the actual cost of the item to the third party producer.
 - (Perhaps counterintuitively, the exporter does not have to consider any specific controls on end user or end use in determining whether content is “controlled.” For example, if an EAR component of a PCBA would not need a license generally to China, then it is not considered “controlled” for the *de minimis* calculation, even if the PCBA is going to be sold to Huawei, where a license is required for all items subject to the EAR under the “Entity List” (discussed below).)

12. *Id.* § 734.4(d)

- This value is then divided by the price (or total production cost if the item has no fair market value or is free) of the foreign-made product in the market where it is sold in order to determine the *de minimis* percentage.¹³
 - If using the production cost method, such cost needs to be calculated using a consistent, commercially reasonable approach. The cost would therefore include a combination of the inputs (*i.e.* the item components purchased or obtained from third parties) and the labor cost associated with developing the item. (For example, this should be approached just as if the company were making a wooden desk where the production cost of the desk would be a combination of the wood used to make it and the labor of the carpenter. If the wood were from the U.S., the % U.S. value for *de minimis* purposes -- if the wood was “controlled” -- would be wood/wood+labor.)

Only for technology (*i.e.* technical information): If the U.S. content is “technology” (*i.e.* if non-U.S. technical information is being commingled with U.S. origin technical information) then the person seeking to transfer the “technology” is required to make a one-time report to the Department of Commerce regarding the mixing of the information before relying on the *de minimis* rule.¹⁴ This reporting requirement does **not** apply to the use of *de minimis* to transfer hardware or software. It only applies to technology transfers.

Note that any U.S.-origin technology used to develop a product is **not** itself counted towards the value of the product for *de minimis* purposes; whether such technology or software is relevant to an item becoming “subject to the EAR” is determined under the next category of items “subject to the EAR”

13. See Supplement No. 2 to Part 734, “Guidelines for *De Minimis* Rules.”

14. 15 C.F.R. § 734.3(c)(3).

(foreign direct product rule). For example, if using a U.S. blueprint to make a microchip, the value of the blueprint (which is not a part of the microchip) is not counted towards the *de minimis* analysis of the microchip. Whether the blueprint renders the microchip subject to the EAR depends on the direct product rule, described below.

2. Foreign Direct Product Rule

Finally, under the EAR, foreign-produced goods that are the direct product of controlled U.S.-origin technology or software or are produced in a foreign plant that is a direct product of U.S.-origin technology or software are only subject to the EAR if they are covered by the “foreign direct product rule.”¹⁵

For most end users, customers, and countries, that rule requires licenses for the export, re-export, or transfer of foreign-produced items only when two conditions are met:

- First, the U.S. technology or software used to make the foreign-produced item must have been transferred to the non-U.S. producer using a special “written assurance” document that the non-U.S. producer would have signed prior to receiving the technology or software.¹⁶ This written assurance requirement would only apply if the technology exported from the U.S. is controlled for “national security” (“NS”) reasons, which means it is very highly controlled.
- Second, the foreign-made item itself must be covered by an ECCN subject to “NS” controls.¹⁷

15. *Id.* § 736.2(b)(3).

16. *Id.* § 736(b)(3)(ii)(A)(1).

17. *Id.* § 736(b)(3)(ii)(A)(2).

The two conditions for export of a foreign-made item produced in a plant that was the product of U.S. technology are similar and also only apply if the technology supporting the plant and the product to be exported are controlled for national security reasons. If both of these conditions are met, the relevant item produced outside the U.S. is “subject to the EAR.”¹⁸ Otherwise, the foreign direct product rule usually does not apply to the foreign-made product, and such items are *not* subject to the EAR.

For example, take a game software that has been developed outside the U.S. Because it is foreign-made, the game software is not a “U.S. origin” item. Even if it is developed using a game development software platform from the United States, it would not be subject to the “foreign direct product rule.” Game software is classified at the EAR99 level if subject to the EAR. Therefore, it would not be NS controlled, and it does not matter at what level the game development platform is controlled.

However, in August 2020, BIS implemented a special rule for Huawei Technology Co. Ltd. and many of its affiliates that are listed on the EAR’s Entity List (collectively, “Huawei”). The Entity List is a blacklist that restricts without a license essentially all exports or transfers to listed entities (such “end user” controls are one of three types of transfer controls described below). For non-U.S. made items involving Huawei, the foreign direct product rule is much broader. The EAR now states that it is a violation to re-export, export from abroad, or transfer (in-country) without a license or license exception certain non-U.S. made items when there is “knowledge” that:

- The foreign-produced item will be incorporated into, or will be used in the “production” or “development” of any “part,” “component,” or “equipment” produced, purchased, or ordered by Huawei; or

18. *Id.* § 736(b)(3)(ii)(B).

- Huawei is a party to any transaction involving the foreign-produced item, *e.g.*, as a “purchaser,” “intermediate consignee,” “ultimate consignee,” or “end-user.”

This is a broad restriction because the EAR defines knowledge broadly, as “not only positive knowledge that the circumstance exists or is substantially certain to occur, but also an awareness of a high probability of its existence or future occurrence. Such awareness is inferred from evidence of the conscious disregard of facts known to a person and is also inferred from a person’s willful avoidance of facts.”

Unlike the ordinary foreign direct product rule, the Huawei-specific rule covers many more items:

- *Direct product of “technology” or “software” subject to the EAR and specified in certain Category 3, 4 or 5 ECCNs.* The foreign-produced item is a direct product of “technology” or “software” subject to the EAR and specified in Export Control Classification Number (ECCN) 3D001, 3D991, 3E001, 3E002, 3E003, 3E991, 4D001, 4D993, 4D994, 4E001, 4E992, 4E993, 5D001, 5D991, 5E001, or 5E991 of the Commerce Control List (CCL) in supplement no. 1 to part 774 of the EAR.
- *Direct product of a plant or major component of a plant.* The foreign-produced item is produced by any plant or major component of a plant that is located outside the United States, when the plant or major component of a plant, whether made in the U.S. or a foreign country, itself is a direct product of *U.S.-origin* “technology” or “software” subject to the EAR that is specified in ECCN 3D001, 3D991, 3E001, 3E002, 3E003, 3E991, 4D001, 4D993, 4D994, 4E001, 4E992, 4E993, 5D001, 5D991, 5E001, or 5E991 of the CCL.

The rule also clarifies that

- A major component of a plant located outside the United States means equipment that is essential to the “production” of an item, including testing equipment.
- A foreign-produced item includes any foreign-produced wafer whether finished or unfinished.

The ECCNs covered by this rule include many common, commercially available technologies. Therefore, for example, if a semiconductor component of a PCBA is made using a common piece of electronic testing equipment that was made using U.S. origin technology covered by one of these ECCNs, that component cannot go to a third party to be incorporated into the PCBA where the PCBA is for Huawei, unless the U.S. government has issued a license covering the component. In short, this new prohibition is very broad, but applies only where Huawei is somewhere within the ultimate supply chain related to the relevant component or product.

Determining whether a given product is subject to the EAR can be a nuanced process. This determination can be made internally by the company or through consultation with BIS. Specifically, exporters may ask BIS for an Advisory Opinion, stating whether for a given end-use, end-user, and/or destination, a license is required or likely to be granted, for a particular transaction.¹⁹ Exporters should be aware that Advisory Opinions do not bind BIS to issuing a license in the future. However, seeking an Advisory Opinion may be recommended in situations involving high risk exports where outside counsel is most equipped to assist.

19. *Id.* § 748.3.

B. Determining Whether a License is Needed for a Particular Item

If an item is “subject to the EAR” under the above analysis, then any transfer of the item to another party (other than a U.S. Person, meaning a U.S. citizen, U.S. permanent resident or qualified refugee/asylee, or U.S. registered company in the United States), even between two non-U.S. parties located in the same country must be checked against the regulations before transfer. The analysis required is a three step process: **classification, destination, evaluation of end use/end user.**

1. Classification

Transferors must review the Commerce Control List (“CCL”), which contains Export Control Classification Numbers (“ECCNs”). ECCNs list specific items and detail the level at which the listed items subject to the EAR are controlled.²⁰ If an item is not listed on the CCL, but is subject to the EAR, then it is classified “EAR99,” a low level catchall category for any item subject to the EAR that is not listed. For example, every pencil, desk chair, t-shirt, and cardboard box in the United States is classified “EAR99.” The classification process can be an intensive and technical effort. If there is doubt regarding the proper classification of an item, guidance can be sought from the U.S. government as well, in the form of a “CCATS” application in which the government will provide the classification. However, companies are empowered to self-classify and there is generally no requirement to confirm classifications with the U.S. government.

20. See Supplement No. 1 to 15 C.F.R. Part 774.

2. Destination

A person seeking to export an item subject to the EAR must then take the relevant ECCN for the item and check the recipient’s country/region:

- If an item is listed on the CCL, transferors must review the Commerce Country Chart and determine whether a license is required for the nationality of the recipient (and the destination country, if different).²¹ The Commerce Country Chart lists every country in the world and the various “reasons for control” listed under each ECCN. If there is an “x” under the “reason for control” for a given country, then a license is required.

For example, ECCN 3A002 controls many high performing electronic assemblies. The box at the top of each ECCN illustrates the item’s reasons for control:²²

3A002 General Purpose “Electronic Assemblies,” Modules and Equipment, as Follows (See List of Items Controlled).

LICENSE REQUIREMENTS
Reason for Control: NS, MT, AT

Control(s)	Country chart (see Supp. No. 1 to part 738)
NS applies to entire entry	NS Column 2
MT applies to 3A002.h when the parameters in 3A101.a.2.b are met or exceeded	MT Column 1
AT applies to entire entry	AT Column 1

If a company wanted to export a 3A002.b item to Algeria, a license would be required because there is an X under “NS Column 2” on the Commerce

21. Supplement No. 1 to 15 C.F.R. Part 738.
22. Part 742 of the EAR details specific characteristics of the various “reasons for control” but the controls can be reduced for the most part to the X’s on the Commerce Country Chart, except where otherwise noted in the EAR.

Country Chart for Algeria. However, if a company wanted to export that same 3A002.b item to Argentina, it would *not* need a license because there is no “X” under “NS 2” for Argentina. We note that there is an “X” for both Algeria and Argentina for “MT Column 1” *but* note above that only items controlled under 3A002.h are controlled for MT Column 1 (note that the box says that “MT applies” only to “3A002.h” and only when certain parameters are met).

SUPPLEMENT No. 1 TO PART 738—COMMERCE COUNTRY CHART

[Reason for control]

Countries	Chemical and biological weapons			Nuclear nonproliferation		National security		Missile tech	Regional stability		Firearms convention	Crime control			Anti-terrorism	
	CB 1	CB 2	CB 3	NP 1	NP 2	NS 1	NS 2	MT 1	RS 1	RS 2	FC 1	CC 1	CC 2	CC 3	AT 1	AT 2
	1	2	3	NP 1	NP 2	NS 1	NS 2	MT 1	RS 1	RS 2	FC 1	CC 1	CC 2	CC 3	AT 1	AT 2
Afghanistan	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X		X		
Albania ^{2 3}	X	X		X		X	X	X	X	X						
Algeria	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X		
Andorra	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X		
Angola	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X		
Antigua and Barbuda	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X		
Argentina	X					X		X	X		X	X		X		
Armenia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X			
Aruba	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X		
Australia ³	X					X		X	X							
Austria ³⁴	X					X		X	X			X		X		

- Under the EAR, for individuals, nationality is determined by the individual’s *most recent* country of citizenship or permanent resident, except that a person holding a U.S. citizenship, a U.S. green card, or certain other U.S. refugee/asylum status is always a U.S. person and exempt from these controls. Therefore, if technology or software is being transferred to an individual, the process works the same but the individual is considered the “country” for purposes of the chart.

- If an item is classified EAR99 then only Part 746 of the EAR must be checked, which covers the specific embargoes on Iran, Syria, North Korea, Crimea, Russia, and Cuba. Currently, EAR99 items are not controlled for Iran under the EAR, but Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) sanctions largely trump the EAR with respect to Iran trade restrictions. OFAC sanctions restrict the export of any item whatsoever from the United States, directly or indirectly, to Iran, but they contain an exception for certain items, including EAR99 items, already outside the United States. If OFAC authorizes an export to Iran, that authorization covers the EAR as well. For Cuba, and other embargoed countries, there may be restrictions under both the EAR and OFAC sanctions, and licenses may be required from both agencies.

3. End Use/End User Controls – Generally

Finally, apart from country-level controls, transferors must also consider end use and end user controls under Section 744 of the EAR. These controls restrict transfers to specific parties, either for specific uses or because of the identity of the party, regardless of the parties’ nationality (for example, an entity in a traditional U.S. ally country can be a restricted end user, or a transfer in support of nuclear weapons needs a license to any country).

In recent years, the U.S. government has greatly expanded the use of end user controls under the EAR, which requires license for certain transfers to specific entities or categories of persons, primarily through the Entity List, and including, as noted above, Huawei. BIS also maintains a list of “Denied Persons” that similarly restricts exports, re-exports, and in country transfers to such entities.²³ Many of the other end use/end user controls are very specific, except for the Military End User rule, discussed below.

23. See <https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/denied-persons-list>.

4. Military End User Rule

In addition, BIS has also recently greatly expanded the so-called “military end use and end user” rule under the EAR that prohibits the export or re-export to, or transfer in, China, Russia, or Venezuela of a wide array of items—including commercial electronics and software and many civil aircraft, vessel, and mechanical parts—for a military end-use or to a “military end user” without a license.²⁴

The rule is expansive because the definition of “military end user” is very broad. The definition includes not only entities traditionally thought of as a military agency, but also many other government entities, as well as private entities that “support” other military end users. In particular, the rule defines “military end user” to mean:

- the national armed services (army, navy, marine, air force, or coast guard), as well as the national guard and national police, government intelligence or reconnaissance organizations, or any person or entity whose actions or functions are intended to support ‘military end uses’²⁵

The rule defines “military end use” to mean:

- incorporation into a military item described on the U.S. Munitions List (USML) (22 CFR part 121, International Traffic in Arms Regulations); incorporation into items classified under ECCNs ending in “A018” or under “600 series” ECCNs; or any item that supports or contributes to the operation, installation, maintenance, repair, overhaul, refurbishing, “development,” or “production,” of military items described on the USML, or items classified under ECCNs ending in “A018” or under “600 series” ECCNs

24. 15 C.F.R. § 744.21.

25. *Id.*

Based on these definitions, the rule is intended to restrict the transfer of any of the items covered by the rule to (aside from government/military agencies) any *private* entity that supports either the military or other suppliers to the military that develop items that would be considered military items under the EAR or the U.S. International Traffic in Arms Regulations (“ITAR”), 22 C.F.R. Parts 120-130. In other words, the rule is very broad in the concept of “who” is a “military end user.”

The language of this prohibition is also broad because it incorporates the EAR’s definition of “knowledge.” The rule specifically prohibits any transfer where the transferor has “knowledge . . . that the item is intended, entirely or in part, for a ‘military end use,’ . . . or ‘military end user[.]’” As noted above, the EAR defines knowledge as “not only positive knowledge that the circumstance exists or is substantially certain to occur, but also an awareness of a high probability of its existence or future occurrence. Such awareness is inferred from evidence of the conscious disregard of facts known to a person and is also inferred from a person’s willful avoidance of facts.”

The result is that any commercial company in China, Russia, or Venezuela that does any work on military grade items or for the military is likely to be considered a “military end user,” and a license is required for exports of items subject to the EAR to such entities even if the exporter knows with certainty that the specific item for export is not for a military use. This raises diligence and compliance costs on exports to these countries, particularly China, because parties now need to determine whether any particular consignee or end-user is a “military end user” subject to this rule, even if the exporter only sells civil items to the particular recipient.

C. License Exceptions

If a license is required for a specific export (for example, to a national of a certain country or an end user), then there may be an applicable “license exception.” For example, License Exception ENC permits the transfer of most encryption items subject to the EAR to most destinations, if a set of procedures to report such transfers are followed.²⁶ If a license exception applies, there is no determination needed by the U.S. government to complete the export — the exporting company must simply follow the relevant procedures. Parties are allowed to rely on exceptions on their own under their own analysis and prerogative. So, in the case of the License Exception ENC, once a report is made, an export can be conducted without any approval or review by the U.S. government.

The EAR enumerates eighteen kinds of license exceptions with varying requirements.²⁷ Some of the more frequently used exceptions include: Shipments of Limited Value (LVS), Shipments to Group B Countries (GBS), Encryption Commodities (ENC), Technology and Software Under Restriction (TSR) and Technology and Software Unrestricted (TSU), Temporary Imports, Exports, Re-exports, and Transfers In-Country (TMP), and Strategic Trade Authorization (STA).²⁸ Companies should consult part 740 of the EAR for a full list of license exceptions, and note that license exceptions do not generally apply to exports controlled under end user or end use controls (such as the Entity List or the “military end user” rule described above).

In addition, Part 740.2 outlines circumstances under which license exceptions would be inapplicable. These circumstances include, but are not limited to: the suspension of a license requirement; the fact that the item may be used for

26. 15 C.F.R. § 740.17.

27. *Id.* § 740.

28. *See* 15 C.F.R. §§ 740.3 to 740.21 for descriptions of the eighteen EAR license exceptions.

“surreptitious interception of wire, oral, electronic communications, or related software” controlled under particular ECCNs; crime control and detection requirements; missile technology control reasons; involvement of sanctioned destinations; and involvement of most “missile technology” controlled or “600 series” items. Companies should ensure that none of those restrictions apply to the particular export in question.

D. General Prohibitions

The requirements of the EAR are essentially summarized in ten “general prohibitions” that apply to the export, re-export, and activities involving items subject to the EAR. The applicability of these prohibitions varies depending on how an item is classified on the CCL; its ultimate export or re-export destination; its ultimate end-user and end-use; the conduct involved; and whether an exception may apply.

The first set of general prohibitions concerns exports, re-exports, and transfers (in-country) and includes:

- General Prohibition One: This prohibition bars the export or re-export of controlled items on the CCL to controlled countries on the BIS Country Chart without a license or license exception;
- General Prohibition Two: This prohibition bars the re-export (and export from abroad) of foreign-made items with greater than a *de minimis* level of U.S. content (controlled on the CCL) to controlled countries without a license or license exception; and
- General Prohibition Three: This prohibition bars the re-export (and export from abroad) of foreign-produced direct products of U.S. technology and software to certain prohibited countries without a license or license exception.

The second set of general prohibitions relates to prohibited end-users, destinations, and activities and includes:

- General Prohibition Five: This prohibition bars exports and re-exports of items subject to the EAR to prohibited end-users or for end-uses without a license;
- General Prohibition Six: This prohibition bars exports and re-exports to embargoed destinations without a license or license exception;
- General Prohibition Seven: This prohibition bars exports, re-exports, and activities by U.S. persons to support proliferation activities; and
- General Prohibition Eight: This prohibition bars exports and re-exports in transit through certain prohibited countries.

Finally, the third set of general prohibitions concerns actions taken with knowledge of a potential EAR violation or actions in violation of order, terms, and conditions and includes:

- General Prohibition Four: This prohibition bars the engagement of actions prohibited by a denial order;
- General Prohibition Nine: This prohibition bars actions that violate the terms and conditions of an export license or license exception; and
- General Prohibition Ten: This prohibition bars knowing engagement in actions with an awareness that a violation has occurred or is about to occur, including the use of any item unlawfully exported.

A violation of any of the general prohibitions can result in an enforcement action. General Prohibition Ten is a common basis for liability for non-U.S. persons because it prohibits the use of items unlawfully exported.

E. Recordkeeping Requirements

The EAR also contains a recordkeeping requirement. Among others, the following records must be preserved under the EAR for five years from the date of export, re-export, or transfer (in-country), or the latest known diversion (*i.e.* unlawful transfer) of the item:

- Export control documents as defined in part 772 of the EAR (including a license and a application for license), except documents submitted electronically to BIS via the SNAP-R system
- Memoranda
- Notes
- Correspondence
- Contracts
- Invitations to bid
- Books of account
- Financial records
- Restrictive trade practice or boycott documents and reports
- Notification from BIS of an application being returned without action; notification by BIS of an application being denied; notification by BIS of the results of a commodity classification or encryption review request conducted by BIS.

Part 762 of the EAR also references numerous other sections of the EAR which separately identify recordkeeping obligations.²⁹ Original records are required, although copies are normally acceptable if they are accurate, legible and durable.³⁰

29. *Id.* § 762.2(b).

30. *Id.* § 762.5.

Chapter 2

Procedures for License Applications

A. How to Apply

Exporters or re-exporters may submit license applications online through the Bureau of Industry and Security (“BIS”) Simplified Network Application Process-Redesign (“SNAP-R”) system.³¹ Applicants should follow the below steps:

- Prior to applying for a license, each applicant must first register online and obtain a Company Identification Number (“CIN”). To register, complete the SNAP-R Online Registration Form:
<https://snapr.bis.doc.gov/registration/Register.do>
- Upon completion of the registration form, applicants will be assigned a CIN and an account with administrator’s privilege will be created.
- Once registered, each applicant can access SNAP-R and apply for a license: <https://snapr.bis.doc.gov/snapr/>

All communication, questions, and requests pertaining to a license application will be made via the online system. Applicants may also use SNAP-R to check on the status of a pending license application. Potential applicants should create a SNAP-R account as soon as possible so they are prepared to submit an application. Registration is free.

31. Bureau of Industry and Security, *Simplified Network Application Process – Redesign (SNAP-R)*, available at <https://www.bis.doc.gov/index.php/licensing/simplified-network-application-process-redesign-snap-r>.

B. What Information is Required

Applicants do not need a purchase order in order to apply for an EAR license, but do need to provide particulars of the transaction. In anticipation of a license application, potential applicants should compile the following information:³²

- Contact information (including name, telephone number, and e-mail address) of the person who can answer questions concerning the application
- Applicant information, including the applicant’s address and Employer Identification Number
- Other party information, if the applicant would like BIS to transmit the approved license to another party designated by it
- The type of application, including export, or re-export
- Prior license information (if applicable) including, the previous license number, the replacement license number, and/or the import certificate country and number
- Information (including name, address, and telephone number) of the purchaser, intermediate consignee, ultimate consignee, original ultimate consignee and/or end-user
- A complete and detailed description of the end-use intended by the ultimate consignee and/or end-user(s)
- Export information for each item, including:
 - Export Control Classification Number
 - Adjusted Peak Performance (if the application includes a digital computer or equipment containing a computer)

32. Supplement No. 1 to 15 C.F.R. § 748.

- Product/model number
- CCATS number (if the applicant has received a classification for the item from BIS)
- Quantity to be exported or re-exported, in terms of the unit commonly used in trade
- Unit price (fair market value) of items to be exported or re-exported and the total price of the items.
- Name of the manufacturer
- Technical description of the item(s), including details necessary to identify the specific item(s)
- Support documentation submitted with the application, as required in accordance with the provisions of part 748 of the EAR

C. Government Review

In reviewing specific license applications, BIS will conduct a complete analysis of the license application along with all documentation submitted in support of the application. In addition to reviewing the item and end-use, BIS will consider the reliability of each party to the transaction and review any available intelligence information.

Typically within a week or so of license application registration, BIS will:³³

- Contact the applicant if additional information is required (*e.g.*, if the license application is improperly completed, or required support documents are missing);

33. 15 C.F.R. § 750.4(c) defines certain time frames for license processing, but in our experience these are not strictly followed.

- Assure the stated classification on the license application is correct;
- Return the license application if it is deemed not complete or if it is determined a license is not required (“Returned without Action” or “RWA”);
- Approve the license application or notify the applicant of the intent to deny the license application; or
- Refer the license application electronically along with all necessary recommendations and analysis concurrently to all agencies unless the application is subject to a Delegation of Authority.

Regardless of BIS’s initial step, all license applications are typically resolved (approved, denied, or RWA) or referred to the President of the United States no later than 90 calendar days from the date of BIS’s registration of the license application. Certain reviews, particularly those requiring referral to the U.S. Department of State, Department of Commerce, and Department of Energy, or coordination with foreign governments, may take longer than others. In addition, if BIS returns a license application due to deficiencies, the resubmitted application will be treated as a new license application for the purpose of calculating processing times. Certain politically sensitive applications, including those involving targeted entities like Huawei, may take many months -- even well past a year -- to be resolved.

D. Increasing Likelihood that Applications Will Be Granted

While there is no specific formula required for a license application to be granted (apart from providing all information required on the application form itself in SNAP-R), we generally recommend attached a “Letter of Explanation” to any license application that explains the background of the transaction, sets

forth all of the relevant parties and items that are the subject of the request, and making national security and foreign policy arguments about why the application should be granted. This is particularly recommended for applications that are more politically sensitive, such as applications to export items to Huawei or to highly sensitive countries, such as China, Russia, and Venezuela.

Specifically, applicants should consider why a license is required for a particular item, particular country, and/or particular end user, and include arguments about why the application should be granted. For example, if a license is required because a Korean entity wants to export a piece of commercially available software or hardware to a “military end user” in China, the applicant should consider that the purpose of the “military end user” rule is to prevent access by the Chinese military to U.S. technology to use it for military purposes. The applicant could therefore explain that for the application, the relevant software or hardware is available widely throughout China already and that the use of the particular software or hardware is not for any military purposes (if that is true). Similarly, the U.S. government’s focus on Huawei has primarily been to restrict the ability for Huawei to proliferate network and communications technology outside of China. Therefore, applications for networking related items are much less likely to be granted than applications for other item (for example, a gaming platform for Huawei phones) and an applicant could consider pointing this out in an application for Huawei not related to the core concerns of the U.S. government.

Chapter 3

Preparation for On-Site Inspection by Bureau of Industry and Security (“BIS”)

Part 762 of the EAR requires individuals and organizations to maintain export records for *five years* from the latest date of export or re-export activity from the United States.³⁴ Organizations must also make those records available upon request for inspection and copying by BIS, the U.S. Customs Service, or any other agency of the U.S. Government.³⁵ While the Department of Commerce encourages voluntary cooperation with inspection requests, the Department may also issue subpoenas requiring persons located in the United States to appear and testify, or produce records.³⁶ These inspections would typically occur where a party is the recipient of items subject to the EAR under an EAR license, or where the companies is seeking a broader authorization, such as under the EAR’s Verified End User (“VEU”) program which provides a favorable licensing status for non-U.S. companies to receive highly controlled items.³⁷

34. The latest date of such export or re-export activities include: (1) the date of any known re-export, transshipment, or diversion of such export; (2) the date of any termination of the transaction, whether formally in writing or by other means; or (3) in the case of records pertaining to transactions involving restrictive trade practices or boycotts, the date the regulated person receives the boycott-related request or requirement. *See* 15 C.F.R. § 762.6(a).

35. *Id.* § 762.2(a).

36. *Id.*

37. *See* 15 C.F.R. § 748.15.

A. Compliance Policies and Programs

Before engaging in EAR-regulated activity, and certainly before any possible on-site inspection, organizations should ensure they have export compliance programs in place. BIS provides a model compliance program at: <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/pdfs/1641-ecp/file>. The EAR enforcement guidelines, 15 C.F.R. Supplement No. 1 to Part 766, also note that the presence of a compliance program is a mitigating factor in determining penalties for any violations subject to an enforcement action. (Other factors include whether there was concealment, whether the violations reflect a pattern of conduct, and whether and how management was involved, among others. All of these factors are influenced by whether an effective compliance program is in place at the company.

Among other things, those programs should include systems for recordkeeping in compliance with the requirements stated in Chapter 1, Section E above, as well as clear policies for employees to report suspected potential violations of the EAR to company compliance personnel. Compliance programs must also reflect management commitment to export compliance and should be issued under the authority of the senior executive of the company. As discussed in more detail below, with certain exceptions, reporting a violation to BIS is not mandated.

BIS emphasizes the need for companies watch for “red flags” when dealing with counterparties that would alert the company to potential export compliance risks. Such red flags include:

- The customer or its address is similar to one of the parties found on the Commerce Department’s [BIS] list of Denied Persons.

- The customer or purchasing agent is reluctant to offer information about the end-use of the item.
- The product's capabilities do not fit the buyer's line of business, such as an order for sophisticated computers for a small bakery.
- The item ordered is incompatible with the technical level of the country to which it is being shipped, such as semiconductor manufacturing equipment being shipped to a country that has no electronics industry.
- The customer is willing to pay cash for a very expensive item when the terms of sale would normally call for financing.
- The customer has little or no business background.
- The customer is unfamiliar with the product's performance characteristics but still wants the product.
- Routine installation, training, or maintenance services are declined by the customer.
- Delivery dates are vague, or deliveries are planned for out of the way destinations.
- A freight forwarding firm is listed as the product's final destination.
- The shipping route is abnormal for the product and destination.
- Packaging is inconsistent with the stated method of shipment or destination.
- When questioned, the buyer is evasive and especially unclear about whether the purchased product is for domestic use, for export, or for re-export.

Due diligence should not stop at red flags, however. Companies should also consider obtaining written commitments in contracts that companies are compliant with U.S. export control law, and other relevant certifications (such as a certification that an item will not be incorporated into Huawei products)

if necessary. The U.S. government also expects companies to take a risk based approach to compliance, so certifications and contract language may not be enough. Companies should consider conducting independent evaluations and diligence on counterparties that raise a compliance risk. For example, if selling to a company previously known to supply Huawei, it would likely not be viewed as sufficient to ask the company to certify in writing it will stop supplying Huawei using the exporter’s products. The exporter should also consider how it can perform independent evaluations or audits of the that company, to confirm compliance.

Finally, compliance programs should encourage individual employees to report suspected violations, and should include a response protocol, such as “Stop, Notify, and Document,” for situations where one suspects a potential violation:

STOP

Immediately stop the transaction, e.g.:

- If a purchase order has been submitted, place the order on hold;
- If an item has shipped but is not yet delivered, determine if it is feasible to stop the shipment;
- If an item has been delivered, do not distribute or use the item; or
- If an item is in use, stop using it and store it in a secure location (quarantine).

NOTIFY

Once a suspected transaction has been stopped, employees must notify the relevant company compliance personnel.

DOCUMENT

Locate and maintain documentation relevant to the transaction. This may include, but is not limited to:

- Purchase Orders/Subcontracts;
- Shipping Documents;
- Receiving Documents such as Packing Slips;
- Correspondence;
- Party Screening Results; and
- Training Reports.

Once the potential violation is reported, the relevant compliance personnel should work with the personnel reporting the incident and management to investigate and determine whether a violation has actually occurred. Research may involve reviewing documentation, interviewing personnel and meeting with vendors and/or customers.

B. Preparing for an Inspection

Because inspections by BIS, or other U.S. Government agencies may be unannounced, companies should also devote substantial resources to the development of compliance plans, recordkeeping systems, and inspection response plans.

First, companies should create a system to manage records based on the recordkeeping requirements of the EAR. Organizations may begin this process by analyzing the day-to-day activities that involve exports and re-exports, and creating a list of documents that must be retained. The types of records to maintain will depend on the nature of the company’s activities and how they

are controlled under the EAR. With that information, organizations should develop procedures on recordkeeping responsibilities and standards. Responsibilities should be clearly allocated among personnel in line-business units, records management, system administration, and elsewhere. Companies should also work to ensure oversight of the recordkeeping process.

After establishing proper recordkeeping procedures and systems, organizations should ensure that all required records are captured and correctly filed to allow for efficient search and retrieval during an investigation. If possible, companies should take into account recordkeeping requirements early in the design or planning stages of information technology development. When building new or enhancing existing systems, companies should take record management into consideration to ensure that all appropriate records are captured and changes in technology do not make records obsolete. Finally, organizations should regularly backup critical data offsite to ensure that systems and servers can be reloaded in the event of accidental error or a system crash.

Next, in anticipation of an inspection, a company should form a Crisis Management Team (“CMT”) and develop a response plan. This will enable the organization and its employees to respond quickly to an unannounced government inspection. The CMT should consist of key employees, including a Site Leader and a Deputy Site Leader for each office to lead the response if and when an inspection occurs. Among other responsibilities, Site Leaders will liaison with government attorneys and agents until outside counsel arrive. Other members of the CMT should include communications staff to handle any media inquiries or statements, information technology personnel to assist in locating electronic information, and other key personnel who are knowledgeable as to the location of the records and are available to observe the search and take notes. In coordination with outside counsel, each company should develop a detailed response plan, outlining specific steps to take during and after the investigation.

Chapter 4

Addressing Potential Violations of the EAR

A. EAR Violations

A violation of any of the general prohibitions discussed above (in Chapter 1, Section D) can result in an enforcement action. In addition, the following actions also amount to violations of the EAR:³⁸

- Acting with knowledge of a violation in the ordering, buying, removing, concealing, storing, using, selling, loaning, disposing of, transferring, transporting, financing, forwarding, or otherwise servicing any item exported or to be exported, that is subject to the EAR, with knowledge that a violation has occurred or is likely to occur;
- Engaging in prohibited conduct by or contrary to, or refrain from engaging in any conduct required by, the Export Control Reform Act (“ECRA”), the EAR, or any order, license or authorization issued there under;
- Causing, aiding, counseling, commanding, permitting, or abetting a violation or an omission of a required act;
- Soliciting or attempting a violation of the EAR, or any order, license or other authorization;
- Conspiring to act in concert with one or more persons in any manner or for any purpose to bring about or do any act constituting a violation or

38. *Id.* § 764.3.

omission of a required act under the EAR, order, license or other authorization;

- Possessing an item controlled for National Security or Foreign Policy reasons with intent to export illegally or with knowledge that the item would be so exported;
- Misrepresenting and concealing facts by making false statements or certifications or falsifying or concealing any material fact either during an investigation or in connection with preparation, submission, use or maintenance of any export control document for the purpose of effecting an export, re-export or other applicable activity;
- Evading the provisions of the EAR or any order, license or other authorization when undertaking transactions subject to the EAR;
- Failing to comply with reporting and recordkeeping requirements of the EAR, or any order, license or other authorization;
- Altering any license, authorization, export control document, or order issued under the EAR, except as specifically authorized in the EAR or in writing by BIS; or
- Acting contrary to the terms of an order issued by BIS.

B. Voluntary Self-Disclosures

The Department of Commerce strongly encourages disclosure to BIS Office of Export Enforcement (“OEE”) when violations of the EAR are suspected. Voluntary Self-Disclosure (“VSD”) may benefit a company, as it is a mitigating factor in determining what administrative sanctions, if any, will be sought by OEE, and is considered together with all other factors in a case. On the other

hand, companies may elect not to disclose a violation in order to avoid unwanted questions or scrutiny from the U.S. Government. Depending on the risk tolerance of an organization, a company may instead prefer to seek guidance from outside legal experts.

If an organization chooses to voluntarily disclose a violation, the company should make an initial notification to OEE as soon as possible after the violation is discovered and then conduct a thorough review of all export-related transactions where violation is suspected. The initial notification should be in writing and should include the name of the person making the disclosure and a brief description of the alleged violations. The notification should describe the general nature and extent of the violations. Once full disclosure is made thereafter, the VSD will have been deemed to have been made on the date of initial notification.

After the initial notification, a thorough review should be conducted of all export-related transactions where possible violations are suspected. Such a review should cover a period of five years prior to the date of initial notification if possible. Upon completion of the review, OEE should be furnished with a narrative account that sufficiently describes the suspected violations so that their nature and gravity can be assessed and should include the following information:

- The kind of violation involved, for example a shipment without the required license or dealing with a party denied export privileges;
- An explanation of when and how the violations occurred;
- The complete identities and addresses of all individuals and organizations, whether foreign or domestic, involved in the activities giving rise to the violations;

- License numbers;
- The description, quantity, value in U.S. dollars and ECCN or other classification of the items involved;
- A description of any mitigating circumstances; and
- The nature of the review conducted and measures that may have been taken to minimize the likelihood that violations will occur in the future.

The narrative account should be accompanied by copies of documents that explain and support it, including:

- Licensing documents such as licenses, license applications, import certificates and end-user statements;
- Shipping documents such as Automated Commercial Environment, Electronic Export Information (ACE EEI) records, air waybills and bills of lading; and
- Other documents such as letters, facsimiles, telexes and other evidence of written or oral communications, internal memoranda, purchase orders, invoices, letters of credit and brochures.

Any relevant documents not attached to the narrative account must be retained by the person making the disclosure until OEE requests them, or until a final decision on the disclosed information has been made. After a final decision, the documents should be maintained in accordance with the recordkeeping rules in part 762 of the EAR.

C. Potential Outcomes Resulting from Enforcement Actions

Anyone who violates the EAR risks significant criminal, administrative, and civil penalties.

The Office of Export Enforcement (OEE) is responsible for investigating any apparent violations and taking appropriate actions based on its findings. OEE utilizes a case-by-case approach in conducting its investigations, and the resulting action or response will depend on the facts and circumstances of each case. There are seven main ways OEE typically responds to investigations of apparent violations. *First*, if it finds that no violation occurred, OEE will issue a no-action letter. *Second*, OEE may find that a violation occurred but a civil penalty is not warranted, and issue a warning letter encouraging compliance with the EAR. *Third*, OEE may conclude that a violation has occurred and that civil monetary penalty or other administrative sanctions are necessary. In that instance, OEE will likely initiate an administrative enforcement proceeding and issue a charging letter. *Relatedly and fourth*, OEE may determine that it seeks only a civil monetary penalty.

Fifth, when appropriate, OEE may seek criminal prosecution for apparent violations and refer the matter to the U.S. Department of Justice. *Sixth*, OEE may respond through other administrative sanctions like license suspension or revocation, denial of export privileges, exclusion from practicing before BIS, and required implementation of training/auditing requirements. This could include placement on the “Denied Persons List” or “Entity List” under the EAR, which in practice restrict or hinder a company’s ability to do any business involving items subject to the EAR. This can have a significantly detrimental effect on supply chain and/or customer access, depending on the restrictions imposed. *Finally and seventh*, OEE may suspend or defer payment of a civil monetary penalty during a probation period under a settlement and BIS order.³⁹

Maximum criminal penalties for EAR violations can result in imprisonment for up to twenty years,⁴⁰ fines of up to \$1 million per violation,⁴¹ and suspension

39. 15 C.F.R. § 766.

or debarment from U.S. government contracting.⁴² Sanctions for EAR violations can also include revocation of export privileges.⁴³ Denial of export privileges under the EAR is not automatic upon conviction, and absent “exceptional circumstances,” a person or organization proposed for denial will be given a chance to comment in writing. BIS will consider mitigating factors in determining whether to revoke export privileges.⁴⁴ If denial of export privileges is imposed as a penalty, however, it can last up to ten years.⁴⁵

For non-U.S. companies, a common enforcement mechanism is also placement on the Entity List, which bans exports of items subject to the EAR without a license. It is very difficult, once placed on the Entity List, to be removed, and while there is an appeals process, non-U.S. companies enjoy few rights in the U.S. to ensure a full and open process.

D. Penalties

In addition to those discussed above, penalties for EAR export violations can be severe. Under the ECRA, the maximum civil penalties for violations imposed are the greater of \$300,000 or twice the amount of the transaction that is the basis of the violation, and criminal penalties. Importantly, the U.S. government can count “violations” in many different ways (by shipment, by item, by date) such that it can arrive at higher or lower penalty calculations depending on the circumstances and as pressure for companies to settle charges voluntarily with the government.

40. *National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019*, H.R. 5515, § 1760(b).

41. *Id.*; 15 C.F.R. § 764.3(b).

42. *See* FAR §§ 9.403, 9.406–2(b)(iv); 15 C.F.R. § 764.3(c)(2)(ii) (noting potential cross-debarment application across enforcement agencies).

43. 15 C.F.R. § 766.25; *id.* § 764.3(a)(2).

44. *Id.* § 766.25(b).

45. *Id.* § 766.25(d).

In addition to monetary penalties, other types of penalties can be imposed as a result of violations, including the following:

- denial, suspension or restriction of export privileges;
- restriction in dealings in which the company may benefit from export or re-export privileges;
- seizure or forfeiture of items intended to be or actually unlawfully exported;
- cross-debarment, including debarment of ITAR export privileges; and
- debarment or suspension from receiving any further contracts with the U.S. Government and,
- substantial negative publicity.

In addition to civil penalties, criminal violations are those that are made willfully and knowingly. Knowledge is a defined term in the EAR and includes not only positive knowledge that the circumstance exists or is substantially certain to occur, but also an awareness of a high probability of its existence or future occurrence. Such awareness is inferred from evidence of the conscious disregard of facts known to a person and is also inferred from a person's willful avoidance of facts.

Conduct that constitutes a violation of the ECRA may also be prosecuted under other provisions of law, including 18 U.S.C. § 371 (conspiracy), 18 U.S.C. § 1001 (false statements), 18 U.S.C. §§ 1341, 1343, and 1346 (mail and wire fraud), and 18 U.S.C. §§ 1956 and 1957 (money laundering).

Appendix

U.S. Sanctions Against Huawei

On May 15, 2019, Huawei and an original set of affiliates were placed on the Entity List. Roughly 60 Huawei affiliates have since been added, now totaling 150. This has caused a significant disruption to Huawei's supply chain and to many U.S. and non-U.S. companies' ability to continue doing business with Huawei. The Entity List only applies, however, to each individual legal entity that is on the list, and restricts only the export of items subject to the EAR to Huawei. Affiliates and subsidiaries of listed entities are not automatically subject to the Entity List's restrictions (although the Department of Commerce cautions that doing business with an affiliate of an Entity List entity is considered a high compliance risk because that affiliate may transfer items subject to the EAR to its listed affiliate).⁴⁶ Transfers of items not subject the EAR are similarly not restricted, although as noted above in Chapter 1, Section A.2, Huawei is subject to a number of specific and expansive controls under the EAR.

46. See BIS FAQs, https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/faqs#faq_134 ("Subsidiaries, parent companies, and sister companies are legally distinct from listed entities. Therefore, the licensing and other obligations imposed on a listed entity by virtue of its being listed do not per se apply to its subsidiaries, parent companies, sister companies, or other legally distinct affiliates that are not listed on the Entity List. If, however, such a company, or even an unaffiliated company, acts as an agent, a front, or a shell company for the listed entity in order to facilitate transactions that would not otherwise be permissible with the listed entity, then the company is likely violating, inter alia, General Prohibition 10, EAR section 764.2(b) (causing, aiding, or abetting a violation) and possibly other subsections of 764.2 as well. Those who export, re-export, or transfer items subject to the EAR with knowledge that the items are destined to a subsidiary, sister, parent, or other affiliate of a listed entity are encouraged to take extra due diligence steps[.]")

In addition, Huawei is not currently on the SDN list, administered by the Office of Foreign Assets Control (“OFAC”), which is a financial sanctions blacklist that prohibits U.S. companies from doing any business with SDNs. However, in the recent “Clean Network” initiative public statement, the U.S. State Department suggested that Huawei is a “human rights abuser”:

- To prevent untrusted PRC smartphone manufacturers from pre-installing—or otherwise making available for download—trusted apps on their apps store. Huawei, an arm of the PRC surveillance state, is trading on the innovations and reputations of leading U.S. and foreign companies. *These companies should remove their apps from Huawei’s app store to ensure they are not partnering with a human rights abuser.*⁴⁷

It is possible, given this language, that the U.S. is considering the use of the SDN List to target additional companies in China. It would be an extraordinary escalation of the U.S.-China trade conflict for the U.S. to place an entity like Huawei on the SDN list, but it is not out of the realm of possibility in the current political environment. The fact that the State Department has called Huawei a “human rights abuser” could be a precursor to an SDN listing.

47. <https://www.state.gov/the-clean-network/#:~:text=The%20Clean%20Network%20program%20is,as%20the%20Chinese%20Communist%20Party.>